Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

Titre I

Les aspects juridiques du démembrement de l'immobilier d'entreprise

250

Le droit de propriété est défini par l'article 544 du code civil : *« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. ».*

Il s'agit d'un droit absolu, perpétuel et exclusif. Le propriétaire est titulaire d'une plénitude de pouvoir sur la chose objet de son droit qu'il exerce principalement par des actes de jouissance et de disposition. Le droit de jouissance lui permet d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, le droit de disposer lui permet d'accomplir tout acte d'aliénation notamment de le vendre, le donner, l'apporter à une société ou même l'abandonner. Il résulte par ailleurs du texte que les pouvoirs du propriétaire ne peuvent être limités que par la loi. Ces limites tiennent alors au droit privé (l'utilisation de la propriété ne peut avoir pour effet de nuire à autrui) et au droit public : l'administration porte en effet des atteintes constantes au libre exercice du droit de propriété dans son essence même (ex. : expropriation) ou dans ses prolongements (ex. : autorisation de construire). La faculté de disposer conférée au propriétaire lui permet de constituer tous droits réels sur la chose objet de son droit ; cette liberté de créer des droits réels de jouissance spéciale a été récemment consacrée par la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt « Maison de Poésie » (cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16.304).

L'article 578 définit l'usufruit comme le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il faut donc considérer l'usufruitier comme un administrateur (F. Zenati, « Les biens », 1re éd., PUF, p. 245). L'usufruit est un droit réel, nécessairement temporaire attaché à la personne conférant à son titulaire un droit à la jouissance et aux revenus du bien (c. civ. art. 582 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=582&idspad=LEGIARTI000006429279)). L'usufruitier a l'obligation de jouir de son usufruit raisonnablement (« en bon père de famille », selon l'expression supprimée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014) c'est-à-dire comme un propriétaire soigneux et diligent (Ripert et Boulanger, Droit civil, Planiol, T. 1, 5e éd., n° 3567).

Le droit réel ainsi créé au profit d'un autre que le propriétaire va s'exercer sur la chose d'autrui. Il confère à son titulaire un pouvoir d'une nature différente de celle du propriétaire. La chose ne lui appartient pas, elle lui est simplement affectée. La constitution d'un droit réel ne provoque pas la disparition du lien de propriété existant entre le propriétaire et son bien, mais octroie une prérogative concurrente, résultant de l'affectation de la chose à un tiers (F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 319). Le nu-propriétaire bénéficie d'un droit réel (Req. 6 mars 1861 : DP 1865.1.417) et a vocation à recouvrer au moment de l'extinction de l'usufruit la totalité des prérogatives du propriétaire : il dispose en quelque sorte d'un droit futur à la pleine propriété. À l'égard de l'usufruitier, le nu-propriétaire a pour seule obligation de permettre à ce dernier de jouir paisiblement du bien grevé d'usufruit ; cette indépendance des droits entre usufruitier et nu-propriétaire distingue cette forme de propriété collective de l'indivision qui, à l'inverse, se caractérise par la concurrence des droits de même nature entre plusieurs titulaires.

Si l'usufruitier ne peut céder la propriété du bien, il conserve toutefois la faculté d'aliéner son usufruit (F. Zenati, « Les biens», précité, p. 248). Ce dernier étant toutefois attaché à sa personne, la durée de l'usufruit en cas de cession d'un usufruit préconstitué est limitée à la personne sur la tête de laquelle il a été constitué, c'est-à-dire le plus souvent à la durée de vie du cédant et non à celle du cessionnaire.

L'usufruitier dispose d'un droit réel (Req. 6 mars 1861 : DP 1865.1.417), c'est-à-dire d'un droit direct et immédiat sur la chose.

Le droit réel de l'usufruitier a une nature immobilière lorsqu'il porte sur un bien immobilier, ou mobilière s'il s'applique à un meuble.

L'usufruit est nécessairement constitué pour une durée limitée, qu'il soit d'origine légale, testamentaire ou conventionnelle.

Pour les personnes physiques, la durée maximale de l'usufruit est la durée de vie de l'usufruitier. L'usufruit est nécessairement temporaire et au maximum viager. S'il est constitué pour la vie de son titulaire, il s'éteindra à son décès. S'il est constitué pour une durée fixe, il s'éteindra au premier des deux événements que constituent l'arrivée du terme ou le décès de son titulaire (cass. ch. réun. 16-6-1933 : DH 1933 p. 393).

Lorsque l'usufruitier est une personne morale, la durée de l'usufruit ne peut être supérieure à trente ans (c. civ. art. 619 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=619&idspad=LEGIARTI000006429628)).

L'usufruit peut être établi au profit d'une ou de plusieurs personnes, immédiatement ou à terme, conjointement ou successivement (usufruit conjoint, usufruit successif).

L'usufruit conjoint est un usufruit détenu conjointement par plusieurs personnes sur un même bien. Si l'usufruit conjoint comporte une clause d'accroissement, au décès du premier usufruitier, le ou les autres usufruitiers se partagent l'accroissement.

L'usufruit est dit successif, lorsque plusieurs personnes sont appelées à jouir successivement de l'usufruit.

L'usufruit fait partie du patrimoine de l'usufruitier : il peut être vendu, donné ou saisi et ce, indépendamment de la nue-propriété.

Cette indépendance a pour conséquence une absence d'indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. En effet, ils sont titulaires de droit de nature différente, si bien qu'ils ne sont pas en indivision. Faute d'indivision, aucun partage n'est possible entre eux.

Ce principe d'indépendance a aussi conduit la jurisprudence puis la loi (c. civ. art. 621 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=621&idspad=LEGIARTI000006429647)) à conclure qu'en cas de vente conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété, le prix doit être ventilé entre eux selon la valeur respective de chacun des deux droits.

Par ailleurs, jouissant temporairement de la chose d'autrui, l'usufruitier est tenu à la fois d'obligations négatives d'abstention (détériorer les biens soumis à son droit) et à un certain nombre d'obligations positives, notamment entretenir les choses en bon état et faire les réparations rendues tant nécessaires par leur usage (ce qui correspond, par ailleurs, à une charge de fruits). Il est également comptable de ses fautes et négligences.

La différence existant entre l'usufruitier et le propriétaire peut être résumée ainsi : le propriétaire jouit et dispose, l'usufruitier ne fait que jouir : le propriétaire dissipe ou change à son gré la substance de la chose ; l'usufruitier doit la conserver, il ne peut la dénaturer, même pour l'améliorer (Trib. Gary, « Discussion devant le corps législatif » ; P.-A. Fenet, « Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil », T. XI, p. 229).

Après avoir rappelé les principes juridiques gouvernant le fonctionnement du démembrement de propriété, on traitera de certains aspects spécifiques propres à sécuriser l'opération de démembrement et notamment, la responsabilité particulière pesant sur l'usufruitier, et la rédaction d'un pacte de préférence entre usufruitier et nu-propriétaire incluse.

Chapitre I - Les droits de l'entreprise usufruitière

251

Les développements qui suivent visent au fond à examiner de manière précise quels sont les pouvoirs de l'entreprise qui va détenir l'usufruit à l'actif de son bilan.

S'agissant de sa nature juridique, le titulaire de l'usufruit dispose d'un véritable droit réel immobilier, susceptible, par exemple, de cession ou d'hypothèque.

Pour l'entreprise usufruitière, les intérêts d'un tel droit réel sont multiples : d'une part, il est un gage de stabilité, donc de pérennité de l'exploitation ; d'autre part, ce droit réel peut être donné en garantie, et améliore donc le crédit de l'entreprise.

À cet égard, les droits de l'entreprise usufruitière consistent essentiellement dans l'usage du bien et la faculté d'en tirer des revenus. Le premier aspect n'appelle pas de commentaires particuliers, sauf à souligner que la détention de cet usufruit permet à l'entreprise d'utiliser le bien à sa guise sans avoir toutes les contraintes liées à un bail commercial, comme c'est le cas lorsqu'elle est simplement locataire de l'immeuble.

Même si ce n'est pas l'objectif poursuivi le plus souvent dans ces stratégies, il se peut que l'entreprise soit amenée à donner les locaux en location.

S'agissant de l'usufruit d'un immeuble, le bail consenti par l'usufruitier est assujettie à un certain nombre de règles spécifiques. Si elle relève du pouvoir de l'usufruitier, la loi protège le nu-propriétaire, en instituant une limite de la durée du bail lui étant opposable dans l'article 595 du code civil. Par ailleurs, le même texte impose le concours du nu-propriétaire pour les baux qui confèrent un droit au renouvellement au locataire. Si bien que le degré de liberté de l'usufruitier-bailleur dépend tant de la durée du bail que de sa nature.

On sera donc conduit à distinguer les baux conférant au preneur un droit au renouvellement, de ceux qui ne le lui confèrent pas.

I. Le régime des baux ne conférant pas de droit au renouvellement

252

L'article 595, al. 1er du code civil autorise l'usufruitier à donner à bail de tous les biens soumis à son droit (meubles, immeubles, fonds de commerce...), mais sa liberté n'est pas totale.

A. Le principe de liberté

253

Le bail est traditionnellement considéré comme un acte d'administration que l'usufruitier peut accomplir seul (c. civ. art. 595 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=595&idspad=LEGIARTI000006429395), al. 1 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1&idspad=LEGIARTI000006419280)er). Toutefois sa liberté est limitée quant à la durée du bail. En matière immobilière, il s'agit, d'une part, des baux relevant du code civil, d'autre part, des baux d'habitation et des baux professionnels, relevant de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 (JO du 8 juillet 1989, p. 8541).

B. La liberté limitée de l'usufruitier

254

La liberté accordée à l'usufruitier de passer seul ce type de baux reçoit trois séries d'exceptions. Les deux premières ont trait à la durée du bail et la troisième au droit des incapacités. Seules les deux premières retiendront ici notre attention.

C. Les baux d'une durée inférieure ou égale à neuf ans

255

Dans le but d'assurer la sécurité du nu-propriétaire, l'article 595, al. 3 édicte une disposition anti-fraude. Les baux inférieurs ou égaux à neuf ans, passés ou renouvelés par l'usufruitier seul, plus de trois ans avant l'expiration du bail en cours s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.

L'objectif visé par le législateur est d'éviter la fraude aux droits du nu-propriétaire qui résulterait d'un renouvellement par anticipation du bail par l'usufruitier.

D. Les baux d'une durée supérieure à neuf ans

256

L'article 595 al. 2 précise que les baux passés par l'usufruitier pour une durée supérieure à neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Ce texte permet de concilier les intérêts du preneur et du nu-propriétaire. Le bail ne disparaît pas en fin d'usufruit. Il demeure opposable au nu-propriétaire pour le temps qui reste à courir, de la cessation de l'usufruit, jusqu'à la période de neuf ans pour lequel le bail a été conclu.

À la fin de l'usufruit, la durée totale du bail est divisée en périodes de neuf ans :

-si l'usufruit a pris fin au cours de la première période, celle-ci pourra seulement être achevée. Au-delà le bail devient inopposable au nu-propriétaire ;

-si l'usufruit s'est achevé au cours d'une période de neuf ans subséquente, le bail ne sera opposable au nu-propriétaire que pour la fin de la période de neuf ans en cours au moment de la cessation de l'usufruit.

EXEMPLE

Arnaud, usufruitier, consent le 4 août 2004 un bail de 20 ans à Dominique. Son fils Antoine est nu-propriétaire :
-Si Arnaud décède en 2006 : le bail sera opposable à Antoine jusqu'au 3 août 2013 ;
-Arnaud décède en 2014 : le bail sera opposable à Antoine jusqu'au 3 août 2022.

Il en va de même si l'usufruit a pris fin par suite du décès de l'usufruitier et alors que le nu-propriétaire serait l'héritier de l'usufruitier.

Cette solution se justifie par le fait que les obligations de l'usufruitier cessent en même temps que l'usufruit. L'usufruitier n'a donc pu transmettre à ses héritiers des obligations, que l'extinction de l'usufruit a fait disparaître (Req. 13 avril 1897 ; DP 1898.1.76 ; S. 1900.1.173 ; voir également Aubry et Rau par Esmein, « Les biens », T. II, n° 423, note 58).

II. Les baux commerciaux

257

Les baux commerciaux et les baux ruraux confèrent au preneur un droit au renouvellement (étant précisé que seul le cas des premiers sera traité dans le présent ouvrage).

L'article 145-1 du code de commerce dispose que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles dans lesquels un fonds de commerce est exploité.

Ces baux sont donc de nature à porter atteinte au droit du nu-propriétaire de recouvrer l'usage de son bien à la fin de l'usufruit.

Excédant les simples actes d'administration, ils constituent des actes graves, qui ne peuvent donc être passés sans le concours du nu-propriétaire (c. civ. art. 595 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=595&idspad=LEGIARTI000006429395), al. 4 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=4&idspad=LEGIARTI000006419283) : L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte).

Toutefois, la qualité de bailleur n'appartient qu'à l'usufruitier : lui seul est engagé envers le preneur (H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, « Leçons de droit civil », T. II, éd. Montchrestien, n° 1676). L'autorisation du nu-propriétaire n'est qu'une simple technique de contrôle ; elle n'a pas pour objet d'investir celui-ci de la qualité de bailleur (S. Crevel, « Usufruit et bail rural », Revue de droit rural, mai 2005, p. 315). Le nu-propriétaire n'intervient pas en tant que partie au contrat, mais uniquement pour le ratifier (L. Lorvellec, « Le bail rural consenti par l'usufruitier », Revue de droit rural 1973, p. 485).

A. Le bail initial

1. Le principe du concours du nu-propriétaire

258

On attire ici l'attention sur un point particulièrement important. Sur ce plan, l'entreprise usufruitière désireuse de donner les locaux en location n'est pas totalement libre.

Même si ce point est discuté, la plupart des auteurs considèrent le bail commercial comme un acte de disposition (V. not. en ce sens : J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, Les principaux contrats spéciaux 2e éd. : LGDJ 2012, n° 21129).

Les dispositions de l'article 595 al. 4 sont d'ordre public (cass. civ., 3e, 26 janvier 1972, BC III n° 69 : « Mais attendu… que l'usufruitier ne peut, en vertu de l'article 595, paragraphe 4, du Code civil, conclure de baux à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire… » ; D. 1975, jurisprudence p. 22, note Penneau ; RTD civ. 1972, p. 619, obs. Bredin ; JCP 1972, T. II, 17104, note G. Goubeaux). Le nu-propriétaire ne peut donc y renoncer par anticipation (voir cependant la discussion infra) ; en revanche, le nu-propriétaire peut donner mandat spécial (par nature révocable) à l'usufruitier à l'effet d'intervenir audit bail commercial et de donner son consentement.

Le consentement du nu-propriétaire doit être spécial et donné en connaissance de cause (cass. civ., 1re, 29 juin 1983, BC I n° 192 ; Defrénois 1984, art. 33267, p. 442, obs. Champenois ; cass. civ., 1re, 16 juillet 1985, BC I n° 223, JCP N 1986, T. II, p. 71, note Slimler). En présence de plusieurs nus-propriétaires, leur accord unanime est requis (CA Paris, 2e ch., 19 novembre 1980 : Jurisdata n° 000412).

Autrement dit, dans cette circonstance, le chef d'entreprise ou la SCI nu-propriétaire doit consentir à la mise en place de ce bail par l'entreprise usufruitière.

259

La signature du bail commercial requiert l'accord exprès du nu-propriétaire. On a souvent tendance à négliger ce point au prétexte que le nu-propriétaire n'est autre que le chef d'entreprise et que nécessairement il est d'accord. Et s'il décède ? Les enfants deviennent nus-propriétaires. Et s'ils venaient à reprocher à l'entreprise de ne pas avoir requis l'accord du nu-propriétaire ? L'entreprise se retrouverait dans une situation juridique dangereuse comme on va le voir ci-après.

Les baux d'une durée maximale de deux ans ne confèrent pas la propriété commerciale (c. com. art. L. 145-5 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L145-5&idspad=LEGIARTI000029108698)). Toutefois, le concours du nu-propriétaire est nécessaire à la validité du bail (cass. civ., 3e, 5 avril 1995, BC III n° 99 ; Defrénois 1995, art. 36214, note C. Atias). En effet, la Cour de cassation a voulu protéger le nu-propriétaire d'un risque de renouvellement, notamment tacite.

Par ailleurs, un argument de texte va dans le sens de la décision de la Cour de cassation. En effet, l'article 595 al. 4 du code civil ne vise pas les baux commerciaux, mais les baux portant sur un immeuble à usage commercial.

2. Le défaut du concours du nu-propriétaire

260

Sauf autorisation judiciaire, le défaut de concours à l'acte du nu-propriétaire est sanctionné par la nullité du bail. L'absence de réponse du nu-propriétaire équivaut à un refus de sa part (CA Poitiers, 3e ch. civ., 27 janvier 2004, n° 01-01163 : Jurisdata n° 2004-263982).

a) Le principe : la nullité du bail

261

L'article 595, al. 4 du code civil ne prévoit pas de sanction expresse au défaut de concours du nu-propriétaire.

La Cour de cassation, saisie de la question, a précisé que la sanction de la règle impérative fixée par l'article 595, al. 4 du code civil est la nullité du bail. Le nu-propriétaire peut invoquer cette dernière sans attendre la fin de l'usufruit (cass. civ., 3e, 26 janvier 1972, BC III n° 69 : « Que la Cour d'appel a retenu à bon droit que l'infraction à cette règle impérative était de nature à entraîner la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui pouvait invoquer celle-ci sans attendre la fin de l'usufruit… » ; JCP 1972, II, 17104, note G. G. ; cass. civ. 3e, 11 février 1975, BC III n° 53 ; cass. civ., 3e, 16 décembre 1987, BC III n° 210).

Il s'agit d'une nullité relative, bien qu'elle protège un tiers au contrat et non un des cocontractants. Elle se prescrit donc par cinq ans (c. civ. art. 2224 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=2224&idspad=LEGIARTI000019017112)). La prescription court du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail et non du jour de la signature de l'acte (cass. civ., 3e, 5 février 2003, BC III n° 27 ; « Mais attendu qu'ayant relevé que ce n'était qu'à la mort de leur père en juin 1995 que les consorts X… étaient devenus propriétaires des terres en litige et avaient pu connaître les baux passés et qu'aucun document n'établissait que les loyers avaient été payés aux enfants de M. Robert X… après la mort de leur père, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité introduite moins de cinq ans après qu'ils ont eu connaissance de l'existence de ces baux n'était donc pas prescrite… » ; cass. civ. 3e, 9 juillet 2003, BC III n° 149).

Point pratique

Afin d'éviter d'attendre l'expiration du délai de 5 ans, il serait possible d'user, à l'égard du nu-propriétaire, de l'action interrogatoire prévue par l'article 1183 du Code civil.

Le preneur, qui prétend que l'action du nu-propriétaire est prescrite, doit prouver que ce dernier a eu connaissance du bail depuis plus de cinq ans (cass. civ., 3e, 22 novembre 1995, JCP N 1997, T. II, 24, obs. Moreau). Par ailleurs, s'agissant d'une nullité relative, elle est susceptible de confirmation.

Deux conséquences majeures résultent du défaut de concours du nu-propriétaire :

-la sanction étant la nullité du bail et non son inopposabilité au preneur, ce dernier n'est pas en droit de terminer la période de neuf ans pour laquelle le bail a été conclu (cass. civ., 3e, 17 juillet 1986, Gaz. Pal. 1986.2.792, note Challine et Le Petit ; JCP 1987, T. II, p. 50, obs. Moreau) ;

-par ailleurs, l'action en nullité peut être intentée sans attendre la fin de l'usufruit (cass. civ., 3e, 26 janvier 1972, BC III n° 69, précité).

Le preneur ne pourrait faire échec à la demande d'annulation qu'en invoquant la qualité de propriétaire apparent du bailleur. La Cour de cassation (cass. civ., 3e, 21 janvier 1981, BC III n° 17) a en effet jugé que « le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire, lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ».

Toutefois, la jurisprudence apprécie restrictivement les critères le permettant (cass. civ., 3e, 27 novembre 1987, Defrénois 1988, p. 483, obs. Vermelle ; cass. civ., 3e, 17 juillet 1992, BC III n° 256 ; cass. civ., 3e, 18 janvier 1995, BC III n° 24 ; cass. civ., 3e, 4 février 1998, BC III n° 26).

Certaines décisions ont également permis d'échapper à la nullité sur la base du mandat apparent, le preneur ayant légitimement pu croire au pouvoir de son cocontractant (cass. civ., 3e, 23 novembre 1988, JCP N. 1990, T. II, n° 1, p. 73, obs. Moreau). Mais la jurisprudence se montre très exigeante à l'égard du preneur et l'erreur légitime qui l'autorise à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire du bail est difficilement reconnue (cass. civ., 3e, 5 avril 1995, BC III n° 99, Defrénois 1995, p. 1457, obs. Atias).

Enfin, la conclusion d'un bail commercial sans autorisation du nu-propriétaire peut constituer une cause de déchéance du droit de l'usufruitier sur le fondement de l'article 618 du code civil (cass. civ., 3e, 4 juin 1975, BC III n° 194 : « Attendu que la conclusion d'un bail commercial sur des lieux destinés à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l'usufruit… »).

b) Le palliatif : l'autorisation judiciaire

262

Si le nu-propriétaire refuse son concours, l'usufruitier devra le sommer à comparaître par acte extrajudiciaire. S'il ne se présente pas, il pourra saisir le juge (CPC, art. 1286 par renvoi de l'article 1270 du même code) par voie de requête afin d'obtenir l'autorisation de passer le bail.

La Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ., 3e, 5 mars 1986, BC III n° 24). Il apprécie notamment les motifs de refus invoqués par le nu-propriétaire.

Le tribunal a la faculté d'accorder une autorisation générale et indéterminée quant à l'identité du preneur et aux conditions du bail (cass. civ., 3e, 29 novembre 1995, BC III n° 246 ; RD Imm. 1996, p. 177, obs. Bergel ; RTD civ. 1996, p. 941, obs. Zenati). Il résulte de cette décision que l'article 595 du code civil ne subordonne l'autorisation de justice à aucune condition.

Le tribunal peut cependant refuser l'autorisation sollicitée si la location est susceptible de devenir préjudiciable au propriétaire (cass. civ., 3e, 4 mars 1987, BC III n° 43). Le tribunal apprécie souverainement les motifs de refus invoqués par le nu-propriétaire (CA Rouen, 28 septembre 1971 : Gaz. Pal. 1974.1, p. 68).

La jurisprudence (cass. civ., 3e, 2 février 2005, BC III n° 30 ; V. Barabe-Bouchard, « Le droit de l'usufruitier de donner à bail commercial des parcelles agricoles », JCP N 2005, n° 23, 1303) semble vouloir adopter comme critère principal la gestion dynamique des biens démembrés et notamment l'examen global de l'intérêt que présente la conclusion du bail pour la bonne exploitation du bien *(« … Mais attendu qu'ayant constaté que le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d'adapter les activités agricoles à l'évolution économique et à la réglementation sur la protection de l'environnement, qu'il ne dénaturait ni l'usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu'il était profitable à l'indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s'engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d'origine, la Cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause… »).*

L'autorisation conférée par le tribunal rend le bail opposable au nu-propriétaire, avec tous les effets qui y sont attachés, y compris le bénéfice du statut des baux commerciaux, et par conséquent de la propriété commerciale (J.-Cl. Not. Form., Bail Commercial, Fasc. 100, n° 57).

3. Les aménagements conventionnels sont-ils possibles ?

263

En d'autres termes, le nu-propriétaire peut-il renoncer par avance au droit qu'il tient de l'article 595, al. 4 ? Peut-on stipuler dans la convention signée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire que l'usufruitier aurait la faculté de passer seul les baux commerciaux ?

À notre connaissance, il n'existe pas de jurisprudence sur le sujet.

Un argument milite dans le sens de cette possibilité. Les tribunaux considèrent en effet que la nullité édictée par le texte n'est qu'une nullité relative et non une nullité absolue. Il paraît donc possible au nu-propriétaire de renoncer par anticipation à se prévaloir des dispositions stipulées en sa faveur par l'article 595, al. 4 du code civil.

Mais, le texte de l'article 595, al. 4 vise le concours du nu-propriétaire et non une simple autorisation de sa part. Faute de jurisprudence en ce sens, nous pensons donc prudent de ne pas stipuler dans la convention de démembrement de propriété que l'usufruitier puisse signer seul les baux conférant droit au renouvellement.

B. Le renouvellement du bail

1. Le principe du concours du nu-propriétaire

264

Le bail signé lors du renouvellement constitue un nouveau contrat (cass. com. 17 février 1998, BC IV n° 72). L'article 595, al. 4 du code civil ne distingue pas entre la conclusion du bail ou son renouvellement. Le concours du nu-propriétaire à l'acte est donc requis (cass. civ., 3e, 24 mars 1999, JCP N 1999, p. 1081, note Pillebout ; J. Mestre, RTD civ. 1999, p. 93) : *« L'article 595, alinéa 4, du Code civil ne comportant aucune distinction entre renouvellement et conclusion du bail initial, le consentement du nu-propriétaire est nécessaire à la validité du renouvellement du bail d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. »*

À titre de règle pratique, on conseillera à l'entreprise usufruitière de ne pas oublier de se rapprocher du nu-propriétaire plus de six mois avant la fin du bail en lui demandant de prendre parti sur le renouvellement.

Bien que la jurisprudence ne soit pas clairement fixée sur la question, nous pensons que l'usufruitier ne peut délivrer seul un congé avec offre de renouvellement, car cela reviendrait en fait pour l'usufruitier à conclure seul un nouveau bail, ce que la Cour de cassation lui interdit.

L'intervention du nu-propriétaire présente un intérêt majeur pour l'usufruitier, celui de s'opposer au renouvellement. Une indemnité d'éviction est alors due au preneur par le bailleur aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce. En pareille hypothèse, il semblerait juste que cette indemnité incombe au nu-propriétaire ayant refusé le renouvellement, plutôt qu'à l'usufruitier.

2. L'exception : l'usufruitier peut renouveler seul les baux ruraux et commerciaux passés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, soit le 1er février 1966

265

L'article 22 al. 1er de la loi du 13 juillet 1965 précise (que) : *« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 595 nouveau du Code civil ne sont pas applicables aux baux en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ni à leur renouvellement. »*

Il s'est agi, pour le législateur, de ne pas porter atteinte aux contrats formés avant son entrée en vigueur.

Les baux commerciaux en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce texte (1er février 1966) sont donc expressément exclus de son champ d'application quel que soit le nombre de renouvellements intervenus (cass. civ., 3e, 9 octobre 1970, BC III n° 511 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bail consenti par l'usufruitier avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, pour une durée qui n'excédait pas 9 ans, était opposable au propriétaire, après extinction de l'usufruit, dans les mêmes conditions que si les z... tenaient de lui leur droit, et que, dès lors, le renouvellement du bail était régi par les dispositions du statut du fermage, auxquelles ne fait pas obstacle l'alinéa 2 de l'article 595 du Code civil, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés » ; cass. civ., 3e, 7 novembre 1972, BC III, n° 585 : « Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute fraude et alors que c'est par la loi du 13 juillet 1965, qui a été déclarée inapplicable aux baux en cours à la date du 1er février 1966 et à leur renouvellement, qu'il a été fait interdiction à l'usufruitier de donner à bail un fonds rural à défaut d'accord du nu-propriétaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; par ces motifs : casse et annule » ; cass. civ., 3e, 4 février 1981, BC III n° 25 : « Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1965, les dispositions du dernier alinéa de l'article 595 nouveau du Code civil ne sont pas applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ni à leur renouvellement... » ; cass. civ., 3e, 15 janvier 1992, JCP N 92, T. II, p. 269 : « Mais attendu que l'usufruitier, qui peut consentir seul au renouvellement d'un bail commercial conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965... »).

En conséquence, les baux consentis par l'usufruitier avant cette date, pour une durée de neuf ans sont donc opposables au propriétaire après extinction de l'usufruit, dans les mêmes conditions que si le preneur tenait son droit de ce dernier.

Chapitre II - Les obligations de l'entreprise usufruitière lors de la création du démembrement

266

L'entreprise usufruitière est tenue à un certain nombre d'obligations visant à assurer la protection du nu-propriétaire (c. civ. art. 600 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=600&idspad=LEGIARTI000006429450) à 604 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=604&idspad=LEGIARTI000006429487)). Ces mesures sont principalement de nature conservatoire (constatation de l'état des immeubles). Comme, en fin d'usufruit, elle doit restituer les choses dans l'état où elle les a reçues, il s'agit de permettre au nu-propriétaire de se préconstituer la preuve de la consistance des biens démembrés au moment de la constitution de l'usufruit. Mais elles ont également pour fonction d'assurer la sécurité du nu-propriétaire en termes de restitution par la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie équivalente.

I. Le constat de l'état physique de l'immeuble

267

L'usufruitier doit entretenir l'immeuble et le restituer à la fin de l'usufruit dans l'état où il l'a reçu. Exerçant un droit de jouissance sur la chose d'autrui (c. civ. art. 578 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=578&idspad=LEGIARTI000006429233)), il doit donc en assurer la conservation (« En droit par application des articles 600 et suivants du Code civil, l'usufruitier a pour obligation première à l'égard du nu-propriétaire de respecter le droit réel de ce dernier » ; CA Orléans, 14 sept. 1988 : Jurisdata n° 1988-044585 ; « Il convient de rappeler que l'usufruitier doit entretenir l'immeuble de telle sorte qu'il puisse le restituer à la fin de l'usufruit dans l'état où il se trouvait à l'ouverture de cet usufruit » ; CA Besançon, 25 mars 1997 : Jurisdata n° 1997-041755).

A. Le principe

268

L'article 600 du Code civil dispose que l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du nu-propriétaire, l'état des immeubles soumis à l'usufruit. Ces prescriptions participent de la sécurité tant du nu-propriétaire que de l'usufruitier. Il importe donc d'y veiller.

En ce qui concerne le nu-propriétaire, il permettra d'établir l'état du bien qui devra lui être restitué à la fin de l'usufruit (cass. civ., 1re, 11 févr. 1959, BC I n° 89, «... que, si aucun inventaire n'a été dressé à cette époque, il appartenait aux propriétaires de le requérir, puisque c'est dans leur intérêt, pour assurer la restitution des biens à la fin de l'usufruit, que l'article 600 du Code civil l'impose aux usufruitiers... »). Or, les mêmes règles s'appliquent à l'inventaire des meubles et à la constatation de l'état des immeubles (J-Cl Civil Code, art. 600 à 604, n° 18).

L'usufruitier, quant à lui, prend les choses dans l'état où elles se trouvent au jour de la création de son droit. L'état de l'immeuble permettra de déterminer la mesure de son obligation de restitution en établissant l'état dans lequel les choses soumises à son usufruit lui ont été remises.

La description de l'état de l'immeuble servira également à déterminer l'étendue de l'engagement de la caution.

1. Le moment

269

L'article 600 du code civil dispose que cet état doit être dressé au moment de l'entrée en jouissance de l'usufruitier (Req. 22 mai 1883, DP 84.1.272). À défaut, il peut être exigé par le nu-propriétaire postérieurement à la prise de possession et pendant toute la durée de l'usufruit (civ. 19 août 1872, DP 1872.I.397), au besoin à l'aide d'une requête du nu-propriétaire adressée au juge des référés (c. proc. civ. art. 808 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070716&numero=808&idspad=LEGIARTI000039623592)), du juge d'instance (c. proc. civ. art. 848 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070716&numero=848&idspad=LEGIARTI000039623700)) ou premier président de la Cour d'appel, lors de l'instance d'appel.

2. La forme

270

L'article 600 du code civil est muet quant à la forme authentique ou sous seing privé. La seule exigence légale consiste dans le contradictoire de l'inventaire.

L'acte authentique présente toutefois deux avantages majeurs :

-il a force exécutoire, ce qui est de nature à conférer une grande sécurité au nu-propriétaire, notamment en cas d'opposition d'intérêt entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ;

-il présente la certitude de la conservation et permet de pallier une des plus grandes faiblesses de l'acte sous seing privé, à savoir le risque de perte. Et ce risque est d'autant plus important que l'usufruit peut durer plusieurs dizaines d'années.

3. Les frais

271

Les frais d'établissement incombent à l'usufruitier. Il s'agit en effet d'une obligation que la loi met à sa charge (Planiol et Ripert, T. 3, 2e éd. par Picard, n° 820).

4. La sanction du défaut d'état de l'immeuble

272

Le défaut de confection de l'état de l'immeuble n'entraîne pas la déchéance du droit d'usufruit (Paris, 2e ch. 21 novembre 1979, Jurisdata n° 0473 : «... Considérant que le défaut de confection de l'inventaire imposé par l'article 600 du même code n'entraîne pas la déchéance du droit d'usufruit, qu'il autorise seulement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à l'usufruit... » ; dans le même sens : Req. 17 juillet 1861, DP 1861.1.480). Proudhon justifie cette solution par l'absence de disposition du Code civil prononçant la déchéance de l'usufruit (« Traité des droits d'usufruit », précité, T. 2, n° 792).

En revanche, hormis l'hypothèse de constitution d'usufruit *per retentionem* (G. Ripert et J. Boulanger, « Traité élémentaire de droit civil », T. II : LGDJ 1952, n° 2973), le nu-propriétaire peut empêcher l'usufruitier de rentrer en jouissance des biens soumis à usufruit tant qu'il n'a pas procédé à l'inventaire (Marty et Raynaud, « Les biens », 2e éd, n° 68, p. 103) et lui refuser la remise des biens (cass. req., 31 mars 1858 : S. 1858.1.458 ; DP 1858.1.194).

5. La preuve de la consistance des biens en l'absence d'inventaire

273

En l'absence d'inventaire, la preuve de la consistance des biens soumis à usufruit pèsera sur le nu-propriétaire. S'agissant d'un fait, elle s'établit par tous moyens (Paris, 2e ch. 21 novembre 1979, précité ; Paris 15 septembre 1993 D. 1993. IR.236).

B. L'exception : la dispense contractuelle d'établissement de l'état de l'immeuble

274

Hormis deux cas particuliers visés par la loi (donations d'effets mobiliers : c. civ. art. 948 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=948&idspad=LEGIARTI000006433853) et libéralités entre époux en présence de descendants : c. civ. art. 1094-3 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1094-3&idspad=LEGIARTI000006435444)), le constituant peut dispenser l'usufruitier d'établir un inventaire (C. Brenner, « L'acte conservatoire », LGDJ, T. 323, n° 692). Ceci ne peut, bien évidemment, avoir pour effet d'empêcher le nu-propriétaire d'y procéder s'il le souhaite (cass. civ., 1re, 4 janvier 1957, BC I n° 1). En effet, le constituant ne peut priver son héritier du seul moyen qu'il ait eu de se ménager une preuve régulière (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit », précité, T. 2, n° 801). Il en supporte alors les frais (Planiol, « Traité élémentaire de droit civil » par Ripert et Boulanger, 5e éd., T. 1, n° 3548).

1. L'intérêt pratique d'y procéder

275

Nous pensons opportun que l'état dans lequel se trouve l'immeuble soumis à usufruit fasse l'objet d'une description précise. L'état de l'immeuble contiendra ainsi l'indication de sa situation matérielle au début de l'usufruit.

L'intérêt est double : juridique et économique d'une part, fiscal d'autre part.

a) L'intérêt juridique et économique

276

Il intéresse principalement les rapports entre l'entreprise usufruitière et le nu-propriétaire (la nue-propriété sera détenue par l'un des dirigeants-actionnaires de la société d'exploitation, soit « en direct », soit par une société civile familiale) au terme de l'usufruit.

Faute d'établissement d'un état de l'immeuble, on pourrait penser que l'entreprise est présumée avoir reçu l'immeuble en bon état de réparation de toute espèce en se référant à l'article 1731 du code civil. Mais ce texte, applicable dans les rapports bailleur-preneur, parce que ce dernier est tenu de rendre la chose au preneur en bon état de réparation de toute espèce (ce qui fait présumer qu'il l'a reçue dans le même état), ne s'applique pas à l'usufruitier qui prend la chose dans l'état où elle se trouve (c. civ. art. 600 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=600&idspad=LEGIARTI000006429450)) et doit la rendre dans le même état.

En matière de démembrement, ce document permettra d'établir avec certitude l'état dans lequel le bien a été reçu par l'usufruitier et donnera la mesure des travaux de remise en état incombant à ce dernier au terme de l'usufruit.

UN BON CONSEIL...

Pour des raisons purement pratiques de conservation, nous conseillons d'annexer l'expertise qui aura été réalisée à la minute de l'acte constatant l'acquisition des droits réels démembrés. La conservation en sera ainsi parfaitement assurée, ce qui n'est pas toujours le cas des documents sous seing privé.

À défaut de réaliser l'état des immeubles avant l'acquisition des droits démembrés, il serait opportun, a minima, que l'acte d'acquisition des droits démembrés organise contractuellement la réalisation de cet état.

b) L'intérêt fiscal

277

Procéder à l'établissement de l'état de l'immeuble présente également un intérêt dans les rapports entre l'entreprise (dont nous présumons qu'elle est usufruitière), le chef d'entreprise nu-propriétaire et l'administration fiscale.

En effet, l'entretien de l'immeuble constitue une obligation légale pour l'usufruitier et la loi lui impose de rendre les choses dans l'état où il les a reçues. Si bien que s'il n'a pas respecté ses obligations, le chef d'entreprise nu-propriétaire sera titulaire, au terme de l'usufruit, d'une créance contre l'usufruitier. La dette dont il s'agit est une dette légale, opposable en tant que telle à l'administration.

L'intérêt fiscal de se préconstituer la preuve de ce rapport d'obligation est évident. Les travaux de remise en état seront déductibles pour l'entreprise, sans entraîner de charge fiscale pour le chef d'entreprise nu-propriétaire. De la sorte, si la société usufruitière est détenue par la même personne que celle qui possède la nue-propriété, la preuve des travaux à effectuer résultant de l'état de l'immeuble empêchera l'administration d'exciper d'un acte anormal de gestion ou d'un abus de bien social. D'autant plus que l'état de l'immeuble ayant été annexé à un acte authentique aura date certaine.

II. La fourniture d'une caution

A. Le principe

278

Pour garantir l'exécution de l'obligation de jouir des biens raisonnablement (en « bon père de famille » selon l'expression d'autrefois) et de restituer les biens reçus dans l'état où il les a reçus, l'usufruitier est tenu par la loi de fournir une caution, sauf s'il en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit (c. civ. art. 601 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=601&idspad=LEGIARTI000029336835)). Les frais sont à sa charge, s'agissant d'une obligation que la loi met à sa charge (J.-Cl. Not. rép. Usufruit, Fasc. 60, n° 164).

Ce texte est de portée générale et s'applique à tous les usufruitiers, à l'exception des père et mère, jouissant de l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants, du vendeur et du donateur, sous réserve d'usufruit. Cette obligation constitue une véritable garantie de passif au profit du nu-propriétaire (S. Chaine et M. Iwanesko, « Le patrimoine au XXIe siècle », 96e Congrès des notaires de France, 4e commission).

L'usufruitier doit donner caution avant son entrée en jouissance. Toutefois, en pratique, cette garantie ne sera constituée qu'après qu'aura été dressé l'état des immeubles, puisque ce dernier détermine l'étendue de la garantie à conférer au nu-propriétaire (Aubry et Rau, « Les biens », 7e éd. par Esmein p. 646).

Attention, si l'entreprise usufruitière ne satisfait pas à ses obligations, le chef d'entreprise nu-propriétaire aura la faculté d'exiger ultérieurement la fourniture de la caution (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit », précité, T. 2, n° 814). S'agissant d'une obligation légale et non d'une garantie conventionnelle, cette faculté est insusceptible de prescription (Rennes, 6 décembre 1900 ; S. 1903.2.208).

En tout état de cause, le nu-propriétaire peut refuser la délivrance des biens soumis à l'usufruit tant que l'usufruitier n'a pas fourni caution (Aubry et Rau, « Les biens », 7e éd. par Esmein, n° 409).

Ainsi, le nu-propriétaire d'un immeuble dont l'usufruit a été légué conserve son droit de rétention sur cet immeuble, faute pour l'usufruitier de donner caution (cass. req., 22 janv. 1878 : S. 1878.1, p. 216 ; DP 1878.1, p. 316). Toutefois, le retard à donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits qui lui sont dus dès l'ouverture de son droit (c. civ. art. 604 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=604&idspad=LEGIARTI000006429487)). Ces derniers lui seront versés par le nu-propriétaire au moment où il aura satisfait à son obligation.

La seule sanction qu'encourt donc l'usufruitier est une entrée en jouissance différée.

Le cautionnement exigé par la loi est un cautionnement simple. En effet, le nu-propriétaire ne saurait contraindre l'usufruitier à donner une caution solidaire, faute d'obligation résultant de la loi. D'autre part, il ne peut en exiger une autre que celle offerte dès lors qu'elle remplit les conditions légales.

L'usufruitier est tenu de donner caution avant l'entrée en jouissance, donc dès l'ouverture de l'usufruit. Toutefois il ne saurait être tenu de conférer cette garantie avant d'avoir procédé à cet inventaire ou à l'état de l'immeuble, puisque ce dernier va préciser l'étendue de la garantie à conférer au nu-propriétaire (Aubry et Rau, « Les biens », 7e éd. par Esmein, p. 646). Si la caution n'a pas été constituée, le nu-propriétaire pourra l'exiger ultérieurement.

La caution doit répondre aux impératifs édictés par l'article 2317 du code civil aux termes duquel : « Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296 ».

La caution doit avoir des biens suffisants pour répondre de l'objet de l'obligation ; (c. civ. art. 2295 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=2295&idspad=LEGIARTI000044071238)) sa solvabilité ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique (c. civ. art. 2296 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=2296&idspad=LEGIARTI000044071234)) et doit être appréciée d'après l'importance des obligations dont elle garantit l'exécution (J.-Cl. Not. Rép., Usufruit, Fasc. 60, n° 148). Enfin, si la caution devenait insolvable, l'usufruitier serait tenu d'en fournir une autre (c. civ. art. 2297 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=2297&idspad=LEGIARTI000044071230)). L'article 2317 du Code civil n'étant pas d'ordre public, le créancier aura la faculté d'accepter comme caution une personne qui ne remplirait pas les prescriptions légales.

Faute de trouver une caution, l'usufruitier a la faculté d'offrir une garantie équivalente. L'article 2318 du code civil dispose à cet égard que celui qui ne peut pas trouver une caution peut donner à la place un gage en nantissement suffisant. Cette garantie peut valablement être constituée par une hypothèque (cass. civ. 7 août 1882 ; S. 1882.1.457 ; cass. civ. 3 février 1897 : DP 1897.1.601), un gage, un nantissement de parts sociales ou une caution bancaire.

En fait, la seule condition requise de la caution est que celle-ci présente une solvabilité suffisante pour répondre tant de la valeur du mobilier que des dégradations pouvant être commises par l'usufruitier sur les immeubles (Aubry et Rau par Esmein, « Les biens », 7e éd., n° 49).

Si l'usufruitier est dans l'impossibilité de donner caution et que l'usufruit porte sur un immeuble, ce dernier est donné à bail ou mis en séquestre (sur les modalités pratiques, voir c. civ. art. 1955 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1955&idspad=LEGIARTI000006445190) et s.).

Aux termes de l'article 604 du Code civil, le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits qui lui sont dus dès l'ouverture de son droit. Le simple retard n'entraîne donc pas de sanction pour l'usufruitier, les fruits lui seront simplement versés par le nu-propriétaire au moment où il aura satisfait à son obligation.

B. L'exception : la dispense de caution

279

Les articles 601 et suivants du code civil n'étant pas d'ordre public, il peut être dérogé à la fourniture de caution. Le nu-propriétaire aura toujours la faculté de demander au juge la fourniture d'une caution si ses intérêts sont menacés.

C. Aspects pratiques

280

Alors que l'état de l'immeuble revêt un intérêt fiscal évident, la fourniture d'une caution ne nous paraît pas fondamentale lorsque les mêmes associés contrôlent la société détentrice de l'usufruit et la nue-propriété.

> Il pourra alors être stipulé dans la convention : « Par dérogation expresse aux dispositions des articles 601 et suivants, le nu-propriétaire dispense expressément l'usufruitier de fournir caution. Il se réserve toutefois la faculté de l'exiger judiciairement s'il estime ses intérêts menacés. »

Chapitre III - Les obligations de l'entreprise usufruitière pendant le démembrement

281

L'usufruitier est astreint à un certain nombre d'obligations pendant la durée du démembrement, tant à l'égard du nu-propriétaire que de l'administration fiscale ou du preneur en cas de bail.

I. Les obligations de l'entreprise usufruitière à l'égard du chef d'entreprise nu-propriétaire

A. Le respect de la substance

282

Aux termes de l'article 578 du Code civil, si elle peut jouir du bien objet de son droit, l'entreprise usufruitière doit en conserver la substance. Il est fait référence en cela à la « salva rerum substantia » (la substance des choses étant conservée) du droit romain. Cette notion est diversement appréciée. Pour certains auteurs, il s'agit d'une définition purement matérielle définie par le propriétaire (en ce sens, voir notamment E. Dockes, « Essai sur la notion d'usufruit », RTD civ. 1995, pp. 486-493). Pour d'autres, il s'agirait plus d'une définition plus subjective. Un auteur y voit les qualités intrinsèques du bien, ses caractéristiques déterminant sa potentialité à produire des avantages utiles à l'être humain (F. Barbier, « Nature juridique de l'usufruit », Th. Doct. Lyon III, 1987, p. 94).

La substance d'un bien se définit traditionnellement comme son affectation normale, sa destination (E. Dockes, « Essai sur la notion d'usufruit », RTD civ. 1995 p. 491).

Il en résulte, pour la doctrine, que l'usufruitier ne peut pas porter atteinte à la matérialité de la chose, ni en modifier la destination, sauf à y être autorisé par les tribunaux (voir Req. 8 avril 1845, DP 1845.1.214 pour la transformation d'une auberge en teinturerie). En effet, l'article 578 du code civil précise que l'usufruitier doit jouir « comme le propriétaire lui-même ». Il doit donc respecter l'affectation donnée par le propriétaire. Il a ainsi été jugé que l'usufruitier ne pouvait donner à bail un bien utilisé pour l'habitation (cass. civ., 3e, 5 décembre 1968, D. 1969.274).

Il jouit, mais comme un propriétaire sage, qui n'abuse point de sa chose et qui est intéressé par sa conservation ; son administration doit être celle du père de famille, même vigilant, qui ne sacrifie point l'avenir au présent, mais qui ménage l'un en jouissant sagement de l'autre (Tribun Gary, « Discussion devant le corps législatif », P.-A. Fenet, « Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil », T. XI, p. 229).

Un auteur relève par ailleurs que la référence au modèle du « bon père de famille » (désormais « personne diligente et raisonnable ») n'impose aucune obligation ni aucun modèle de gestion à l'usufruitier, elle lui interdit seulement de compromettre, par son mode de jouissance, l'exécution de son obligation de restitution (D. Fiorina, « L'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières », RTD civ. 1995, p. 59).

B. L'obligation d'entretien

283

Le code civil répartit les charges afférentes à l'immeuble entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (art. 605 à 607 et 1244). Il distingue les réparations d'entretien qui incombent à l'usufruitier, des grosses réparations auxquelles le nu-propriétaire est tenu.

La distinction entre réparations d'entretien et grosses réparations est fondée sur le fait que les premières sont une charge de la jouissance, alors que les secondes sont une charge de la propriété (rép. civ. Dalloz V° Usufruit, spéc. n° 385).

Il convient donc d'abord de préciser le sens du mot « réparations » avant de déterminer la personne de son titulaire.

Ces dernières ont pu être définies ainsi : *« Le mot réparation s'entend de tout ouvrage qu'on fait à une chose dégradée, afin d'en prévenir la ruine et de la remettre en l'état où elle doit être pour remplir convenablement les fonctions auxquelles elle est destinée. »* (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie », 1re éd. 1824, T. IV, n° 1612). L'auteur observe que l'action de réparer suppose la préexistence de la chose. S'il en allait autrement, il s'agirait d'une construction neuve et non d'une réparation.

Ceci posé, quel est le champ d'application des textes en présence ?

Art. 605 : *« L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ».*

Art. 606 : *« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ».*

Art. 607 : *« Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit ».*

La difficulté de distinction entre grosses réparations et réparations d'entretien tient à l'archaïsme du texte. En effet, l'article 606 du code civil n'est que la reprise de l'article 262 de la Coutume de Paris régissant la question sous l'ancien droit (P. Courbe, « L'entretien de la chose soumise à usufruit », JCP N. 1983, I, p. 227).

La Cour de cassation considère que l'appréciation du caractère des réparations est une question de fait relevant du pouvoir souverain du juge du fonds : *« Attendu, d'une part, que… que l'appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée a l'appréciation des tribunaux… »* (cass. civ., 2e, 7 décembre 1961, BC II n° 842) ; *« Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'au sens de l'article 606 du Code civil, les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale, et souverainement retenu… »* (cass. civ., 3e, 13 juillet 2005, BC III n° 155).

En pratique, les réparations d'entretien recouvrent tous les travaux qui ne sont ni de reconstruction, ni de rétablissement (Aubry et Rau, « Cours de droit civil français », T. 2, § 231, n° 433).

Les grosses réparations, en revanche, sont définies par leur nature. Ce sont celles qui sont inhérentes à la pérennité de la structure du bâtiment. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle précisé que les réparations des gros murs auxquelles s'applique l'article 606, sont celles qui touchent à la maçonnerie de ces murs pour en conforter la solidité (Trib. civ. Seine, 2 février 1944, D. A 1944, J 72). Pour savoir si les travaux doivent être mis à la charge du nu-propriétaire, il convient de se poser la question de savoir si les travaux envisagés portent, ou non, atteinte à la structure même de l'immeuble.

Les grosses réparations sont alors celles que nécessitent des dégradations portant atteinte à la stabilité ou à la durabilité de la construction (P. Courbe, « L'entretien de la chose soumise à usufruit », précité spéc. n° 22 ; Paris, 2e ch., 11 janvier 2000 précité ; Paris, 23e ch., sect. B, 1er juillet 1999, cité in « Le contentieux de l'usufruit », panorama Jurisdata, JCP N. 2000, n° 40).

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient confirmer les principes dégagés par la doctrine. Dans une décision rendue en matière de bail, la Cour a précisé que les grosses réparations ne concernent pas uniquement les éléments énumérés par l'article 606 du code civil, mais plus généralement, celles qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale : *« Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'au sens de l'article 606 du Code civil, les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale… »* (cass. civ., 3e, 13 juillet 2005, BC III n° 155).

Les travaux de grosses réparations sont ceux destinés à remédier aux désordres affectant la solidité de l'immeuble ou son infrastructure et le rendant impropre à sa destination (CA Bordeaux, 2e ch., 26 sept. 2007, n° 06/05334 : Jurisdata n° 2007-343923).

Le critère résiderait dans la nature des travaux à effectuer et non dans l'importance de la dépense.

S'il s'agit de travaux destinés à consolider l'immeuble, ils incombent aux nus-propriétaires. Ainsi, la réfection d'un mur pignon participe de la restauration de la structure même de l'immeuble. Le nu-propriétaire doit donc la supporter (Paris, 1er juillet 1999, Jurisdata n° 023735). Il en résulte qu'un simple ravalement de façade sera à la charge de l'usufruitier (cass. civ., 1re, 21 mars 1962, BC I n° 175). En revanche, si le ravalement nécessite une reprise du gros œuvre, il est alors qualifié de grosse réparation (cass. civ., 3e, 12 avril 1995, BC III n° 103).

Si les principes paraissent simples, l'application pratique des textes n'est pas toujours aisée. En outre, les impératifs de gestion s'accordent mal avec l'indépendance qui gouverne les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Toutefois, les dispositions légales ne relèvent pas de l'ordre public. Aussi le titre constitutif pourra-t-il stipuler des règles particulières, en fonction des besoins des parties : « Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de vente…, les acquéreurs s'obligeaient à faire effectuer, à leurs frais, toutes les réparations qui deviendraient nécessaires

à la maison vendue ; qu'ainsi, la Cour d'appel a relevé l'existence d'une clause dérogatoire à l'article 605 du Code civil… d'où il suit que le moyen n'est pas fondé… » (cass. civ., 3e, 9 octobre 1985, BC III n° 119).

Par ailleurs, les spécificités résultant du régime de la copropriété (loi 65-557 du 10 juillet 1965 et décret 67-223 du 17 mars 1967), imposent de distinguer les immeubles soumis à ce statut et ceux qui n'en relèvent pas.

C. L'obligation d'entretien dans l'immeuble non soumis au statut de la copropriété

1. Les articles 605 et 606 et les obligations incombant au nu-propriétaire

a) Le principe

284

La charge des grosses réparations incombe au nu-propriétaire, sauf si elles ont pour cause le défaut d'entretien. Dans ce dernier cas, elles sont mises à la charge de l'usufruitier à titre de sanction.

b) Les limites au principe

Le nu-propriétaire ne peut être contraint par l'usufruitier d'effectuer les travaux

285

Le nu-propriétaire supporte les dépenses de grosses réparations. Toutefois, il ne peut être contraint par l'usufruitier de procéder aux travaux. Son refus de les effectuer ne peut être attaqué, même au prétexte de l'abus de droit (Paris, 27 juillet 1928, DP 1929.2.1, note Josserand).

En effet, l'article 605 du code civil ne prévoit aucune sanction à l'encontre du nu-propriétaire défaillant. En outre, ce texte n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble : *« Attendu, en second lieu, que les juges d'appel après avoir souverainement énoncé, sans se contredire, que la disposition figurant au contrat susvisé et mettant à la charge de berges, pendant la durée de l'usufruit, toutes les réparations imposées "par la loi" ne constituait pas une dérogation aux principes applicables en la matière, en ont déduit, à bon droit, que l'article 605 du Code civil n'autorisait pas celle-ci à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit »* (cass. civ., 3e, 30 janvier 1970, BC III n° 83).

Cette absence d'obligation s'explique par la nature du droit de propriété. Ce dernier est un droit absolu, aussi le propriétaire a-t-il le droit de faire, ou de s'abstenir de faire (c. civ. art. 544 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=544&idspad=LEGIARTI000006428859)). Mais c'est également un droit exclusif et l'exclusivité du droit de propriété empêche les tiers de pouvoir prétendre à exercer des pouvoirs sur la chose objet de son droit (rép. civ. Dalloz : Usufruit n° 364). L'usufruit est en effet une charge réelle qui n'impose au nu-propriétaire aucune obligation positive (rép. civ. Dalloz : Usufruit n° 364).

Le nu-propriétaire n'est tenu que d'une simple obligation d'abstention envers l'usufruitier. S'il doit le laisser jouir, il n'est pas tenu de le faire jouir (à la différence du bailleur envers le locataire – c. civ. art. 1719 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1719&idspad=LEGIARTI000020459127) et loi 89-462 du 6 juillet 1989 art. 6 b et c). Il est simplement tenu de ne pas entraver l'exercice du droit de l'usufruitier (F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 319). Le nu-propriétaire ne peut pas être contraint d'assurer l'exercice du droit de l'usufruitier ou de le faciliter par des faits actifs.

La jurisprudence confirme de manière constante cette analyse doctrinale. Elle précise que le nu-propriétaire ne peut être contraint de procéder aux grosses réparations (Paris 27 mai 1936 : S. 37.2.42 ; Rouen 31 octobre 1973, Gaz. Pal. 1974.1, somm. 115 ; plus récemment : cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-18.537, F-P+B : JurisData n° 2013-029985). Les tribunaux refusent en conséquence toute action en justice à l'usufruitier pour contraindre le nu-propriétaire à effectuer les travaux (req. 10 décembre 1900, DP 1901.1.209, note Guenee ; S. 1904.1.36) : *« Attendu que de l'article 605 du Code civil,… il résulte que la loi n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit ; que cette solution résulte, d'ailleurs, de la nature même de l'usufruit qui n'impose au nu-propriétaire aucune obligation positive, mais le force seulement à souffrir sur le fonds l'exercice du droit de l'usufruitier… ».*

L'usufruitier (ou ses ayants-droit) qui effectue les dépenses de grosses réparations a un recours contre le nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit

286

Si l'usufruitier réalise les travaux de grosses réparations, il a un recours contre le nu-propriétaire car il n'acquitte pas sa dette propre, mais celle du propriétaire (Proudhon, précité T. IV, n° 1685).

En revanche, les dépenses d'entretien lui incombent définitivement, quelle que soit l'augmentation de valeur qui en résulte pour le propriétaire (Proudhon, précité T. IV, n° 1617).

Le recours dont bénéficie l'usufruitier est fondé sur la théorie de l'enrichissement sans cause (Aubry et Rau, T. 2, § 233, n° 440 et § 235, n° 453 ; Planiol et Ripert, T. 3 par Picard, n° 878 ; P. Courbe, JCP N. 1982, I, 3070, nos 39 et s.) en vertu de laquelle, nul ne doit s'enrichir sans cause juridique aux dépens d'autrui. L'action de in rem verso (action regroupant l'enrichissement sans cause et la répétition de l'indu) est alors ouverte à la personne qui ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit (cass. civ. 12 mai 1914 : DP 1918.1.41, note Naquet).

Par ailleurs la Cour de cassation subordonne le succès de l'action de in rem verso à la condition que le demandeur n'ait pas accompli dans son intérêt personnel l'acte qui l'a prétendument appauvri (J.-Cl. Not. Rép., V° Enrichissement sans cause, n° 35).

Mais le remboursement des travaux de grosses réparations ne peut être exigé par l'usufruitier avant l'extinction de l'usufruit et uniquement à concurrence de la plus-value conférée à l'immeuble par les travaux (cass. civ. 17 juillet 1911, D. 1911.1.457).

En effet, contraindre le nu-propriétaire à rembourser immédiatement la plus-value conférée par l'usufruitier serait de nature à la contraindre à faire une avance pour un bien dont l'usufruitier seul perçoit des revenus et de prélever ces sommes sur son patrimoine (Paris 2e ch., 31 octobre 1961, Gaz. Pal. 1962.1.257).

En outre, la Cour de Paris indique qu'autoriser le remboursement immédiat de la plus-value constituerait pour l'usufruitier un moyen de contraindre le nu-propriétaire à effectuer les travaux (dans le même sens P. Courbe, et Proudhon, T. IV, n° 1687, précités).

Une cour d'appel a toutefois permis à l'usufruitier d'exercer l'action de in rem verso dès la fin des travaux (CA Paris, 27 juill. 1928 : DP 1929.2, p. 1, note L. Josserand ; S. 1930.2, p. 73, note E. Chavegrin).

Si le nu-propriétaire est l'héritier de l'usufruitier, la créance s'éteindra par confusion.

Mais la solution peut avoir des conséquences pratiques si la nue-propriété est aliénée. En effet, s'agissant d'une dette réelle, l'usufruitier aura un recours contre le cessionnaire de la nue-propriété pour la plus-value qu'il aura occasionnée. En pareil cas, pour éviter que l'acquéreur ne paie deux fois la plus-value résultant des travaux, il conviendra que le prix de cession tienne compte de cet état de fait.

Pour assurer toute sécurité à l'usufruitier, on lui conseillera, lorsqu'il aura fait l'avance des frais de grosses réparations, de faire constater par acte extra- judiciaire la nécessité des travaux à effectuer, ainsi que le refus du nu-propriétaire d'y procéder. Cela confortera sa position s'il intente l'action de *in rem verso*.

2. Les articles 605 et 606 et obligations incombant à l'usufruitier

a) Principe

287

L'article 605 du code civil édicte un double principe.

L'usufruitier est tout d'abord tenu des réparations d'entretien. Cette obligation trouve sa source dans l'obligation légale qui lui est faite de conserver la substance de la chose dans l'intérêt du propriétaire (c. civ. art. 578 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=578&idspad=LEGIARTI000006429233)). La

jurisprudence confirme cette analyse (cass. civ. 1re 27 juin 1925 ; S. 25.1.142) : *« Vu les articles 578, 601 et 605 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes de ces articles, l'usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille, de conserver la substance de la chose, et par suite, de faire aux immeubles les réparations d'entretien… »*.

En outre, l'usufruitier supporte les grosses réparations rendues nécessaires par le défaut d'entretien. Il s'agit alors d'une sanction. N'ayant pas respecté ses obligations, il assume la charge des grosses réparations qui en sont la conséquence.

Ce texte ne régit toutefois que la relation usufruitier/nu-propriétaire. Il est inopposable aux tiers avec qui ils auront pu contracter.

Ainsi, un usufruitier qui aurait consenti un bail, serait tenu envers le preneur de toutes les réparations nécessaires destinées à entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle aura été louée alors même qu'il s'agirait de dépenses de grosses réparations (cass. soc. 20 mai 1949. D. 1949.424). En effet, l'usufruitier est tenu, à l'égard de son locataire, de toutes les obligations nées du contrat de bail, et notamment de faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives, sans qu'il y ait ici à distinguer entre les réparations d'entretien et les grosses réparations (rép. civ. Dalloz V° Usufruit, n° 378). Étant toutefois précisé que le locataire n'a aucune action directe contre le nu-propriétaire, faute de rapport juridiquement entre eux.

Dans un but probatoire, on conseillera donc à l'usufruitier de faire constater par acte extra-judiciaire les travaux de grosses réparations, afin de faciliter son remboursement au terme du démembrement.

b) Les sanctions du principe

288

Le nu-propriétaire a une action contre l'usufruitier pour le contraindre à exécuter ses obligations. La jurisprudence a reconnu très tôt au propriétaire les droits qu'il tient de la loi (cass. civ., 1re, 27 juin 1925 ; S. 25.1.142) : *« Vu les articles 578, 601 et 605 du Code civil ; – Attendu qu'aux termes de ces articles, l'usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille, de conserver la substance de la chose, et par suite, de faire aux immeubles les réparations d'entretien ; – Qu'il est de principe certain que toute obligation engendre une action pour son accomplissement, du moment qu'elle existe, et que celui qui y a un intérêt né et actuel à son exécution, peut l'exiger sans délai, à moins de disposition contraire ; – Qu'il n'y a aucune loi qui autorise l'usufruitier à différer ou suspendre l'exécution de l'obligation qui met à sa charge les réparations d'entretien, et le nu-propriétaire a un intérêt né et actuel à ce qu'elles soient faites sans délai, afin de conserver la substance de la chose et d'en prévenir le dépérissement ; qu'il peut par conséquent, contraindre l'usufruitier à les faire au moment où elles sont reconnues nécessaires… »*.

Par ailleurs, lorsque des travaux d'entretien sont nécessaires, l'accord de l'usufruitier n'est pas obligatoire, bien que cette charge lui incombe (ex. : en matière de ravalement de façade : cass. civ., 1re, 21 mars 1962, BC I n° 175 ; JCP 63, éd. N, 13272).

Faute par l'usufruitier de déférer à l'injonction du nu-propriétaire, ce dernier pourrait demander au juge la cessation de l'usufruit pour abus de jouissance, en application de l'article 618 du code civil (cass. civ., 3e, 12 mars 1970, BC III n° 205, D. 1970.692).

3. L'article 607 du code civil

289

Ce texte précise que ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Selon la doctrine, ce texte joue un rôle propre, distinct de celui de l'article 605, dont il constitue une exception. Son champ d'application serait réservé aux ruines partielles, aux réparations d'entretien rendues nécessaires par la vétusté ou le cas fortuit et à une catégorie particulière de grosses réparations, les réfections (M. Lucas de Leyssac, « L'article 607 du Code civil », RTD civ. 1978, pp. 757 et s.).

4. L'article 1244 du code civil

290

Aux termes de l'article 1244 du Code civil (anciennement numéroté 1386), tout propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est causée par un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Ce texte déroge au principe général de responsabilité pour faute institué par l'article 1240 (anciennement numéroté 1382) du code civil. Il permet d'engager la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en établissant le défaut d'entretien ou le vice de construction et non pas la faute du propriétaire, comme l'exige l'article 1240.

Son champ d'application est limité. Le préjudice subi par la victime doit être causé par la ruine du bâtiment, c'est-à-dire son écroulement ou son effondrement, total ou partiel, ne résultant pas d'une intervention volontaire (Casson, « La responsabilité du fait des bâtiments », Les petites affiches, n° 73 du 19 juin 1995).

En matière de démembrement, la Cour de cassation a condamné solidairement les deux titulaires du droit de propriété à la réparation du préjudice. La solution se justifie selon Proudhon par le fait que la loi ne parle pas du propriétaire par opposition à l'usufruitier, mais de celui ou de ceux auxquels appartient la propriété du fonds. La responsabilité dérive de l'absence d'entretien commis par l'un ou l'autre ou les deux titulaires des droits démembrés (Proudhon, précité, T. IV, n° 1724).

D. L'obligation d'entretien dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété

291

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, les dispositions spécifiques résultant de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967 se combinent avec les dispositions de droit commun.

En effet, le règlement de copropriété est opposable tant au nu-propriétaire qu'à l'usufruitier (art. 4 du décret). Par ailleurs, la répartition des charges doit s'effectuer selon les dispositions des articles 605 et 606 du code civil (Paris, 2e ch., 11 janvier 2000, cité in « Le contentieux de l'usufruit », panorama Jurisdata, JCP N 2000, n° 40). Il a ainsi été jugé que l'usufruitier devait assumer les frais de ravalement, les dépenses d'administration de l'immeuble, les frais de fonctionnement des services collectifs et éléments d'équipement communs, ainsi que les primes d'assurances collectives (Paris, 23e ch., sect. B, 1er juillet 1999, cité in « Le contentieux de l'usufruit », panorama Jurisdata, JCP N. 2000, n° 40).

Deux types de dispositions spéciales trouvent à s'appliquer. Les premières sont afférentes au droit de vote dans les assemblées générales des copropriétaires. Les secondes fixent le régime de répartition des charges.

1. Le droit de vote

292

Lorsqu'un lot de copropriété est démembré, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont représentés par un mandataire commun (sauf disposition contraire du règlement de copropriété). À défaut d'accord, ce dernier sera désigné par le président du Tribunal de grande instance par voie d'ordonnance (art. 61 du décret) à la requête de l'un des intéressé ou du syndic (art. 23 al. 2 de la loi).

2. La répartition des charges

293

L'obligation à la dette doit être distinguée de sa contribution.

a) L'obligation à la dette

294

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose *« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges (...) »*.

Le paiement des charges constitue ici une sujétion liée à la qualité de copropriétaire (Rép. civ. Dalloz : copropriété des immeubles bâtis, n° 671) et le syndicat agit alors comme un créancier des copropriétaires (cass. civ., 3e, 30 octobre 1984, BC III n° 180).

Ce texte relève de l'ordre public et ne distingue pas les qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire. Précision doit toutefois être faite que l'article 1er al. 2 du décret du 17 mars 1967 dispose que le règlement doit comporter l'état de répartition des charges prévu à l'article 10 de la loi et que cet état en définit les différentes catégories.

Le démembrement est opposable au syndicat à compter de sa notification au syndic (décret du 17 mars 1966, art. 6). Ce dernier doit donc, au moment de l'appel des charges correspondant au lot considéré, procéder à une ventilation entre les charges imputables à l'usufruitier et au nu-propriétaire. Si l'acte opérant le démembrement prévoit une clause spéciale suivant laquelle l'usufruitier est le seul débiteur des charges, le syndic devra en faire application et l'usufruitier continuera à être le seul redevable de toutes les charges.

Certains règlements comportent des clauses de solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire pour le paiement des charges. Cette pratique a été condamnée par la doctrine faute de reposer sur une base textuelle (M. Dagot, « Le lot de copropriété indivis », JCP, éd. N 1979, p. 454) et par la jurisprudence (Paris 4 décembre 1985 I.R. copropriété, avril 1986, p. 67 ; Paris 23e ch., sect. A, 24 novembre 1999, Jurisdata n° 101.117).

b) La contribution à la dette

295

La loi de 1965 et son décret d'application sont muets sur la répartition des charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. On devra donc se référer à la distinction « charges d'entretien/grosses réparations », prévue par le droit commun. Toutefois, les règles spécifiques au statut de la copropriété peuvent déroger aux principes généraux des articles 605 et suivants du code civil.

Les grosses réparations incombent au nu-propriétaire

296

Nous avons vu que le nu-propriétaire ne peut être contraint par l'usufruitier de procéder aux dépenses de grosses réparations. En revanche, le syndicat peut l'y obliger (CA Lyon, 1re ch., 20 avril 1967, info rapide copropriété 1969, p. 29). Le nu-propriétaire est en effet tenu par la loi au règlement des charges. En tant que propriétaire, l'article 10 de la loi et le règlement de copropriété lui sont opposables (CA Lyon, 1re ch., 20 avril 1967 précité).

Les réparations d'entretien incombent à l'usufruitier

297

Il s'agit des charges ordinaires payées sur les revenus. Parmi ces dernières figurent notamment : les frais de gestion, de réparation, d'entretien, de fonctionnement des parties communes (espaces verts, frais d'eau ou d'électricité...).

La jurisprudence indique par ailleurs que les frais de ravalement de façade constituent des dépenses d'entretien en raison de leur caractère périodique (trib. civ. de la Seine, 2 février 1944, D.A. 1944, p. 72 ; cass. civ. 21 mars 1962, D. 1962, sommaire p. 102 ; voir également JCP 1963, T. II, 13227).

E. Les charges ordinaires de l'article 608 du code civil

298

L'article 608 du code civil dispose que « L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. ».

Il est donc tenu d'acquitter seul, et sans répétition contre le nu-propriétaire, les charges afférentes aux revenus. Il supporte définitivement le paiement de la taxe foncière (CGI art. 1400 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=1400&idspad=LEGIARTI000034110958), II), l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière.

F. Les charges extraordinaires de l'article 609 du code civil

299

L'article 609 du Code civil dispose qu' *« À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :*

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. »

Ce texte fixe la contribution de l'usufruitier et du nu-propriétaire relativement aux charges pouvant être imposées sur la propriété pendant le démembrement. Le principe est que le nu-propriétaire est obligé de les payer : l'usufruitier doit alors lui tenir compte des intérêts. Toutefois, si ce dernier en fait l'avance, le nu-propriétaire devra le rembourser au terme de l'usufruit.

1. Le champ d'application du texte

300

Il s'applique aux dépenses que l'on est obligé de faire et auxquelles on peut être contraint. Il s'agit des contributions aux sommes capitales, qui peuvent être assises sur la propriété par quelque acte de l'autorité publique, attendu que tel est le sens naturel du mot imposer, d'où dérive celui d'impôt (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie », 1re éd. 1824, T. IV, n° 1855).

L'article 609 est donc applicable à l'impôt de plus-value (dans le même sens Aubry et Rau par Esmein, T. II, Les biens n° 434), sauf l'application de textes spéciaux, notamment pour les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens (CGI art. 150 U (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=150%20U&idspad=LEGIARTI000051202598) et s.) et plus-values sur titres (CGI art. 150-0-A).

Mais il serait également applicable à des prescriptions impératives de nature administrative (ex : raccordement au réseau collectif d'assainissement, mise aux normes d'un bâtiment imposé par des considérations tirées de l'ordre public : hygiène, sécurité, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc.).

Contrairement à ce qui est prévu par l'article 612 du code civil pour les dettes successorales, le propriétaire est tenu de payer. Il ne pourrait s'y soustraire en provoquant la vente de la chose soumise à usufruit (Aubry et Rau précité n° 434 ; Proudhon, « Traité des droits d'usufruit », précité n° 1863).

2. La gestion de l'article 609 du code civil

a) Le principe

301

Le propriétaire est tenu de supporter les charges extraordinaires et l'usufruitier, doit lui verser l'intérêt de ces sommes durant toute la durée du démembrement.

b) L'exception

302

L'usufruitier peut accepter de faire l'avance de la dépense. Il sera alors remboursé au nominal par le nu-propriétaire au terme de l'usufruit. S'agissant d'une faculté expressément réservée par la loi, l'administration ne saurait en déduire qu'il s'agit d'une libéralité consentie par l'usufruitier au nu-propriétaire.

3. Les conséquences pratiques

303

Le principe posé par le texte est que le nu-propriétaire paie les travaux et que l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Ce dernier peut toutefois faire l'avance des sommes qui lui seront remboursées au terme du démembrement.

La loi offre donc un arbitrage à l'usufruitier.

a) Le nu-propriétaire paie

304

Dans le silence de la loi sur la nature de l'intérêt applicable, un accord devra être trouvé entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (taux d'intérêt légal, taux des prêts immobiliers...). À défaut, c'est le juge, saisi par la partie la plus diligente, qui le déterminera.

EXEMPLE

L'administration impose des travaux de mise aux normes du bâtiment d'un montant de 50 000 €.

La durée résiduelle de l'usufruit est de 10 ans.

Les parties s'accordent sur un taux d'intérêt égal aux prêts immobiliers d'une durée de 10 ans, soit par hypothèse, pour simplifier, 4 %.

L'usufruitier devra donc verser annuellement 5 000 € au nu-propriétaire.

Soit en valeur actualisée au même taux : 24 736 €.

b) L'usufruitier fait l'avance

305

Le nu-propriétaire remboursera alors l'usufruitier au nominal au terme de l'usufruit en vertu du principe du nominalisme monétaire découlant de l'article 1895 du code civil qui fait obstacle à toute réévaluation (J. Carbonnier, droit civil, T. 3, « Les Biens », 12e éd., p. 175). Ce principe a en effet été institué par le Code civil après le retour à la monnaie métallique par réaction contre les désordres causés par l'instauration des assignats (loi du 7 germinal an XI). La somme énoncée est en effet considérée comme une monnaie de paiement et non comme une monnaie de compte. Le paiement est alors libératoire unité pour unité, sans égard au pouvoir d'achat des unités (H. Roland et L. Boyer, Adages du Droit Français, Litec 3e, pp. 279 et s.).

EXEMPLE

Si l'on reprend les données de l'exemple ci-dessus, l'usufruitier paie immédiatement les 50 000 € qui lui seront remboursés dans 10 ans, soit en valeur actualisée au taux de 4 % : 45 264 €.

S'il dispose de 50 000 €, il aurait pu les placer à 4 % et aurait eu à terme 55 231 €. Le coût à terme est de 55 231 – 45 264 = 9 967 €, soit actualisé à 4 % : 27 180 €.

c) La stratégie à adopter

306

Si l'usufruit et la nue-propriété sont détenus dans des sociétés appartenant à la même personne, on aura tout intérêt à faire payer l'usufruitier.

En effet, cette méthode évite au nu-propriétaire de faire une avance importante de trésorerie. Par ailleurs, la faculté de choix étant laissée aux parties par le texte, elle pourra être constatée par la convention.

Condition tenant aux charges extraordinaires

Il résulte de l'article 609 du code civil qu'à *« l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit »*.

Les parties décident que lesdites charges seront avancées par l'usufruitier et que le capital en sera répété au nominal à la fin de l'usufruit.

Notons qu'il s'agit d'une obligation de faire, dont le défaut n'est sanctionné que par des dommages-intérêts. Si l'on souhaite permettre à l'usufruitier d'obtenir l'exécution forcée (cass. civ., 3e, 27 mars 2008 n° 07-11271 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=07-11271&sp=/juri/inca/global/civile/JURI/TEXT/00/00/18/13/20/JURITEXT000018132070.xml&date=2008-03-27)), il conviendra de le stipuler expressément, ainsi que le permet la jurisprudence.

II. Les obligations de l'entreprise usufruitière à l'égard du preneur

307

Les articles 605 et suivants du code civil réglementent le régime des réparations de l'immeuble démembré. Mais ces règles, issues du droit des biens, ne régissent que les rapports usufruitier/nu-propriétaire.

La relation usufruitier-bailleur/preneur est en revanche régie par le droit commun des baux et les textes spéciaux résultant de la nature du bail (baux ruraux, baux commerciaux, baux professionnels et d'habitation).

Si le nu-propriétaire n'est tenu que d'une simple obligation d'abstention envers l'usufruitier (le laisser jouir), l'usufruitier-bailleur est, quant à lui, tenu d'une prestation positive envers le preneur (le faire jouir).

L'entreprise usufruitière qui consent un bail est donc tenue de toutes les obligations du bailleur à l'égard de son locataire (cass. civ., 2e, 7 décembre 1961, BC II n° 842 : « ...Qu'en la circonstance celui-ci ayant été consenti par veuve Becora, usufruitière, celle-ci était tenue de toutes les obligations du bailleur à l'égard de ses locataires... »).

Elle doit alors, en sa qualité de bailleresse, faire toutes les réparations qui s'avèrent nécessaires pour entretenir le bien loué en état de servir à l'usage prévu au bail (cass. soc. 20 mai 1949, D. 1949, p. 424), y compris de grosses réparations (CA Paris, 27 juillet 1928, DP 1929.2, p. 1, note L. Josserand). Il en irait ainsi même si le preneur était le nu-propriétaire qui aurait refusé de financer les grosses réparations (CA Angers, 2 novembre 1959 : Gaz. Pal. 1960.1, p. 49).

On voit donc bien ici l'intérêt pour l'entreprise d'avoir contractualisé l'engagement du chef d'entreprise nu-propriétaire de financer les travaux de grosses réparations.

Outre les obligations de droit commun de délivrance, d'éviction ou de son fait personnel, l'entreprise est tenue, s'agissant des baux à usage d'habitation :

-des dispositions de l'article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 (délivrer au locataire un logement décent en bon état d'usage et de réparation, le garantir des vices et défauts de nature à faire obstacle à une jouissance paisible, entretenir les locaux et y faire toutes réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués) ;

-de délivrer un logement décent (art. 6, al. 1, nouveau de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 187-II : JO 14 décembre 2000, puis par l'article 142 de la loi 2018-1021 (/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2018-11-23&numero=2018-1021%20&etat_initial=JORFTEXT000037639478&etat_maj=LEGITEXT000037642121)du 23 novembre 2018) ;

-d'effectuer toutes les réparations autres que locatives. L'article 6-C de la loi du 6 juillet 1989 mettant ces réparations à la charge du bailleur, tenu aux termes de ce texte *« d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués »*.

L'entreprise est donc tenue envers le preneur d'effectuer les grosses réparations, alors qu'il n'en est pas tenu à l'égard du nu-propriétaire.

En effet, en tant que bailleur, il a obligation de mettre et de maintenir en bon état pour l'usage auquel ils sont destinés les locaux loués (cass. soc, 20 mai 1949, BC III, n° 433 ; D. 1949, p. 424 ; RTD civ. 1950, p. 199, obs. Carbonnier ; CA Poitiers, 17 mars 1954, D. 1954, p. 560 ; Gaz. Pal. 1954.2, p. 32). L'attendu de la chambre sociale est très net : *« Mais attendu que l'art 605 ne règle que les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et que l'action du fermier était essentiellement fondée sur l'art. 1719 al. 2, d'après lequel, en cours de bail, le bailleur est tenu de faire toutes les réparations qui s'avèrent nécessaires pour entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que cette obligation du bailleur de procurer au preneur la jouissance des lieux revêtant un caractère indivisible à l'égard de ce dernier, il suit que l'usufruitière, qui est tenue de respecter les baux passés par elle-même, a la charge d'assurer leur parfaite exécution… »*

En principe, l'entreprise ne peut exercer de recours contre le chef d'entreprise ou la SCI nue-propriétaire qu'à l'issue de l'usufruit. Le recours est limité à la plus-value conférée à l'immeuble par les travaux de grosses réparations (civ. 17 juillet 1911, DP 1911.1.457).

On reviendra sur les aspects fiscaux de cette situation dans la troisième partie de cet ouvrage (voir § 500 (20190730150406293.html#500) et s.).

REMARQUE
Un bon conseil

Afin d'assurer la sécurité financière de l'usufruitier, on veillera donc à prévoir contractuellement l'obligation pour le chef d'entreprise ou la SCI nue-propriétaire d'effectuer ces travaux.

I – CHARGES D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE : RÉGIME LÉGAL

A- IMMEUBLE NON LOUÉ

1 – Immeuble non soumis au statut de la copropriété		
Relations juridiques usufruitier/nu-propriétaire		
	Usufruitier	**Nu propriétaire**
Obligation à la dette	Entretien - sanction : déchéance de l'usufruit	
	Grosses réparations si elles sont dues à un défaut d'entretien depuis le début de l'usufruit - sanction : déchéance de l'usufruit	Grosses réparations (art. 605) : pas d'action pour l'usufruitier Charges imposées à la propriété (art. 609) : action du tiers contre le nu-propriétaire

Contribution à la dette	Entretien : contribution définitive	
	Grosses réparations (art. 605) – si avance faite : remboursement au terme de l'usufruit – si défaut d'entretien : contribution définitive	Grosses réparations (art. 605) : contribution définitive
	Charges imposées à la propriété (art. 609) si avance de l'usufruitier : remboursement au nominal à la fin de l'usufruit	Charges imposées à la propriété (art. 609) contribution définitive : l'usufruitier rembourse les intérêts
2 – Immeuble soumis au statut de la copropriété		
Relations juridiques avec le syndicat des copropriétaires		
Obligation à la dette	Entretien : titulaires de l'action : syndicat et nu-propriétaire	
	Grosses réparations si elles sont dues à un défaut d'entretien depuis le début de l'usufruit : titulaire de l'action : nu-propriétaire : sanction : déchéance de l'usufruit	Grosses réparations : titulaire de l'action : syndicat / action récursoire contre l'usufruitier si défaut d'entretien
Contribution à la dette	Entretien : dépense définitive	
	Grosses réparations (art. 605) si avance faite remboursement au terme de l'usufruit	Grosses réparations (art. 605) : contribution définitive
	Charges imposées à la propriété (art. 609) si avance de l'usufruitier ; remboursement au nominal à la fin de l'usufruit par le nu-propriétaire	Charges imposées à la propriété : (art. 609) : le nu-propriétaire paie ; l'usufruitier lui tient compte des intérêts

B – IMMEUBLE LOUÉ

A – Immeuble hors copropriété
1 – Relations juridiques usufruitier / nu-propriétaire

Obligation à la dette	Entretien : titulaire de l'action : nu-propriétaire : sanction : déchéance de l'usufruit	
	Grosses réparations si elles sont dues à un défaut d'entretien depuis le début de l'usufruit : titulaire de l'action : nu-propriétaire : sanction : déchéance de l'usufruit	Grosses réparations : pas d'action de la part de l'usufruitier
Contribution à la dette	Entretien : contribution définitive	
	Grosses réparations : si avance faite remboursement au terme de l'usufruit sauf si elles résultent d'un défaut d'entretien	Grosses réparations (art. 605) contribution définitive
	Charges imposées à la propriété (art. 609) si avance de l'usufruitier ; remboursement au nominal à la fin de l'usufruit par le nu-propriétaire	Charge imposée à la propriété : application de l'article 609 du code civil : le nu-propriétaire paie ; l'usufruitier lui tient compte des intérêts
2 – Relations juridiques avec le locataire		
Obligation à la dette	Entretien : obligation contractuelle : art. 1719 al 2° C. civ : titulaire de l'action : preneur : sanction : déchéance du bail (et nu-propriétaire cf. supra)	
	Grosses réparations : obligation contractuelle : art. 1719 al. 2° C. civ. : titulaire de l'action : preneur : sanction : déchéance du bail	
Contribution à la dette	Entretien : contribution définitive	
	Grosses réparations : en vertu du contrat de bail, l'usufruitier doit effectuer ces réparations Si défaut d'entretien, il supporte définitivement ces dépenses	Grosses réparations : le tiers ne peut le contraindre à effectuer les travaux faute de rapports juridiques entre eux
B – Immeuble en copropriété loué		
Relations juridiques avec le syndicat et le locataire		
Obligation à la dette	Entretien et gros œuvre vis-à-vis du locataire	Gros œuvre vis-à-vis du syndicat

Contribution à la dette	Entretien : le syndicat peut le contraindre à effectuer ces travaux Grosses réparations (2 possibilités) : - si défaut d'entretien : il supporte définitivement ces dépenses - dépense imposée par le locataire (hors le cas de défaut d'entretien alors on applique l'article 609) : il y a répétition du capital en fin d'usufruit (au nominal)	Grosses réparations : le syndicat peut le contraindre à effectuer les travaux : mais application de l'article 609 : le nu-propriétaire paye ; l'usufruitier lui tient compte des intérêts (taux légal)

II – CHARGES D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE : RÉGIME CONVENTIONNEL

1- Rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire entre eux		
Obligation à la dette	Déterminé par la convention	Déterminé par la convention
Contribution à la dette	Déterminé par la convention	Déterminé par la convention
2 – Relations juridiques avec les tiers		
La convention est inopposable aux tiers (sauf à l'acquéreur de l'immeuble si elle a fait l'objet d'une publicité foncière), mais action récursoire possible entre usufruitier et nu-propriétaire dans le cadre de la convention.		

III. Les obligations de l'entreprise usufruitière en matière d'assurance d'immeubles

308

Les obligations de l'usufruitier participent toujours du même principe. Exerçant un droit de jouissance sur la chose d'autrui, l'usufruitier est comptable de sa restitution envers le propriétaire au terme de son droit.

S'agissant d'immeubles, il doit souscrire deux assurances. Une assurance de choses destinée à compenser la perte du bien assuré et une assurance de responsabilité destinée à couvrir sa responsabilité à l'égard du nu-propriétaire.

A. L'assurance de choses

309

Elle a pour fonction essentielle de compenser la perte des biens de l'assuré, sans recherche de responsabilité. Elle peut être souscrite par toute personne ayant intérêt à la conservation de la chose (c. ass. art. L. 121-6 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073984&numero=L121-6&idspad=LEGIARTI000006792296) : « Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un r isque peut faire l'objet d'une assurance. »).

Il n'est donc pas nécessaire d'être le propriétaire pour assurer un bien. L'usufruitier et le nu-propriétaire, peuvent donc assurer le bien démembré. Plusieurs solutions sont alors possibles : chacun d'eux peut assurer la valeur de son propre droit, mais, un seul d'entre eux peut également assurer la totalité. L'article L. 112-1 du code des assurances dispose en effet (que) : *« L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. (...) ».*

L'assurance peut donc être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est alors seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

1. Usufruitier et nu-propriétaire assurent chacun leur droit

310

Ils vont donc co-souscrire la police, chacun pour la valeur de leur droit et paieront la prime correspondante.

Si une indemnité est perçue en remplacement du bien détruit du bien, et à défaut de stipulation dans l'acte, l'usufruit se reporterait par subrogation réelle sur l'indemnité sous la forme d'un quasi-usufruit (TGI Paris 27 janvier 1973, J. Notaires 1973, p. 1021, note Viatte, cité in Nota-Bene n° 10, janvier 1996, Cridon Bordeaux Toulouse ; CA Paris 11 juillet 1973, cité par P. Sirinelli, « Lequasi-usufruit », Les Petites Affiches 1993, p. 21, n° 106).

Mais l'acte créant le démembrement peut stipuler que l'indemnité servira à la reconstruction du bien détruit. Il pourra également prévoir que l'usufruit se reportera sur l'indemnité d'assurance et organiser les modalités pratiques de restitution. Enfin, on pourra également stipuler une répartition de l'indemnité d'assurance entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

EXEMPLE

À l'occasion d'une vente ou d'une donation de nue-propriété, on pourra stipuler :

« Le bien ci-dessus désigné sera assuré conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ces derniers souscriront une police auprès de la compagnie X et chacun d'eux paiera la quote-part de la prime correspondant à la valeur de son droit, évaluée selon la méthode du cash-flow actualisé, ainsi qu'il sera dit ci-après…

En cas de sinistre…

Variante 1 : … les sommes versées par l'assureur seront affectées à la reconstruction à l'identique du bien sus désigné. Les présentes seront notifiées à l'assureur susnommé par les soins de…

Variante 2 : … les sommes versées par l'assureur seront réparties entre les divers titulaires au prorata de la valeur de leur droit déterminée selon la méthode du cash-flow actualisé, ainsi qu'il sera dit ci-après…

Variante 3 : … les sommes versées par l'assureur ne seront pas réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, mais feront l'objet d'un quasi-usufruit au profit du premier dont les modalités pratiques sont ci-après arrêtées…».

2. Le contrat est souscrit par l'usufruitier seul

311

C'est généralement le cas lors des donations consenties par les parents au profit de leurs enfants. L'usufruitier agit alors tant pour son compte que celui du nu-propriétaire.

3. Le contrat a été initialement souscrit par le propriétaire et le bien a été ultérieurement démembré

312

L'article L. 121-10 du code des assurances, dispose (qu') *« En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes ses obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat (…) »*.

Comme nous l'avons vu ci-dessus, trois possibilités sont envisageables : soit affecter l'intégralité de la somme perçue à la reconstruction, soit procéder à la ventilation des sommes entre les divers titulaires, soit un quasi-usufruit se reportant sur l'indemnité (P. Sirinelli, « Le quasi usufruit », précité, n° 105 et la jurisprudence précitée).

B. L'assurance responsabilité

1. Le principe

313

La prudence conduit à conseiller à l'usufruitier de souscrire une assurance responsabilité.

En effet, l'usufruitier est responsable de la perte du bien envers le nu-propriétaire sur le fondement de l'article article 578 du code civil. Or, la responsabilité pesant sur l'usufruitier n'est pas une responsabilité subjective (dont il est possible de se libérer en prouvant son absence de faute), mais une responsabilité objective, dont il ne peut s'exonérer en prouvant une absence de faute (cass. civ., 3e, 26 juin 1991, BC III n° 198 ; «… l'usufruitier d'un immeuble, qui a la charge de le conserver et de le rendre, est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l'immeuble, objet de l'usufruit, a péri dans un incendie, sauf à lui, comme tout débiteur de corps certain, de justifier que la chose a péri par cas fortuit… »).

Par voie de conséquence, en cas de sinistre, la compagnie d'assurance, subrogée dans les droits du nu-propriétaire sur le fondement de l'article L. 121-12 al. 1er du code des assurances (*« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »*) peut réclamer à l'usufruitier le remboursement des indemnités versées au propriétaire, sauf à ce que la perte par cas fortuit soit établie (cass. civ., 1re, 10 juillet 1995, BC I n° 319) *«… Mais attendu qu'après avoir retenu que l'usufruitière était responsable envers la nue-propriétaire de l'incendie, la cour d'appel a constaté que l'assurance souscrite par la première comportait une garantie contre les recours des voisins et des tiers ; qu'elle a estimé à bon droit que la nue-propriétaire, victime de l'incendie, était un tiers par rapport à l'usufruitière, assurée responsable de ce sinistre et que dès lors le groupe Azur, subrogé dans ses droits et actions, était fondé à demander à l'assureur de l'usufruitière le remboursement de l'indemnité versée… ».*

L'usufruitier a donc tout intérêt, à s'assurer contre ce risque.

Sur le plan pratique, dans la majorité des cas (ex : donation par les parents aux enfants avec réserve d'usufruit), l'usufruitier continue d'assurer le bien auprès de son assureur. L'assurance-incendie couvre alors la valeur de la pleine propriété de l'immeuble tant pour son propre compte, que pour celui du nu-propriétaire.

L'assurance-incendie souscrite par l'usufruitier pour le compte du nu-propriétaire sera alors assortie d'une assurance responsabilité au profit de l'usufruitier. Elle permet ainsi de garantir la perte du droit propre de chaque partie sans craindre une action en responsabilité contre l'usufruitier, tant de la part du nu-propriétaire, que de l'assureur subrogé dans les droits de ce dernier.

Plus rarement, l'usufruitier et le nu-propriétaire vont s'assurer individuellement auprès de deux assureurs différents pour la perte de leurs droits propres (ex. : vente de la nue-propriété). On conseillera alors à l'usufruitier de souscrire en outre une assurance de responsabilité pour le couvrir à l'égard de l'assureur du nu-propriétaire des conséquences de la perte de la nue-propriété.

2. L'exception

314

Les principes vus ci-dessus connaissent une exception lorsque l'usufruitier est un proche parent du nu-propriétaire, car il bénéficie alors d'une immunité prévue par la loi (art. L. 121-12 al. 3 du code des assurances : « Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »).

Chapitre IV - Le terme du démembrement et les obligations de l'entreprise usufruitière

I. Les causes de l'extinction de l'usufruit

315

Droit de jouissance sur la chose d'autrui, l'usufruit est essentiellement temporaire et au maximum viager. Il est affecté d'un terme extinctif certain (en cas d'usufruit à durée déterminée) ou incertain (en cas d'usufruit viager).

Par ailleurs, et même s'il a été stipulé pour une durée temporaire, il ne peut excéder la durée de vie de la personne sur la tête de laquelle il repose, ou la durée de trente ans s'il s'agit d'une personne morale.

Ces grands principes appelleront, ci-après, quelques précisions.

316

Les causes d'extinction sont énoncées par l'article 617 et suivants du Code civil (étant observé que l'énumération légale est incomplète : elle omet notamment l'extinction par usucapion d'un tiers, l'annulation, la résolution ou la révocation).

Il résulte de ce texte que *« L'usufruit s'éteint :*

Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi ».

Dans le cadre du présent ouvrage, seuls les deux premiers modes d'extinction visés par l'article 617 du code civil retiendront notre attention. Ainsi que la durée spécifique applicable aux personnes morales (c. civ. art. 619 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=619&idspad=LEGIARTI000006429628) : « L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. »).

A. La disparition de l'usufruitier

317

Que l'usufruit ait été stipulé pour une durée limitée (terme fixe) ou viagère, il est habituellement considéré qu'il s'éteint nécessairement avec son titulaire, personne physique ou personne morale.

1. L'usufruitier personne physique

318

Lorsque l'usufruit est constitué par un propriétaire au profit d'une personne physique, il s'éteindra nécessairement au décès de cette dernière.

Lorsque l'usufruit est constitué au profit d'une personne physique pour une durée déterminée (terme fixe), la doctrine considère que cet usufruit s'éteindra néanmoins au décès de l'usufruitier si ce dernier disparaît avant le terme convenu ; c'est la raison pour laquelle, il est traditionnellement considéré que l'usufruit est par essence temporaire et, au maximum, viager.

L'usufruit est intransmissible à cause de mort et ne peut survivre à la personne sur la tête de qui il a été constitué, quand bien même il aurait été stipulé pour une durée limitée et que le terme ne serait pas survenu.

En d'autres termes, lorsqu'on aura constitué un usufruit à durée déterminée sur la tête du chef d'entreprise, personne physique, il cessera au décès de ce dernier quand bien même le terme stipulé ne serait pas survenu (cass. civ. 18 juillet 1923 : D. 1931, 2, p. 75, sous-note a : « Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué ; que loin d'en prolonger la durée, le temps ainsi fixé ne peut que l'abréger lorsque l'usufruitier est encore vivant à l'expiration de ce délai… »).

L'extinction de l'usufruit consécutive au décès de l'usufruitier constitue une disposition d'ordre public. Toute disposition conventionnelle visant à proroger la durée de l'usufruit au-delà de la vie de l'usufruitier est nulle (Aubry et Rau, T. 2, § 234, n° 443 ; Planiol et Ripert, T. 3, par Picard, n° 862). La jurisprudence de la Cour de cassation le confirme (Ch. réunies, 16 juin 1933 : DH 1933, p. 393 : « Attendu que tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe, s'éteint de plein droit par la mort de l'usufruitier »).

C'est pourquoi la disposition de l'article 1975 du code civil, concernant la rente viagère, aux termes de laquelle le contrat est nul si la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat est inapplicable à la constitution d'usufruit (cass. civ. 12 novembre 1930 : DP 1932.I, p. 28 ; Gaz. Pal. 1930.2, p. 925).

La question est différente s'agissant du transfert d'un patrimoine à un autre d'un usufruit préconstitué, par exemple la cession d'un droit d'usufruit viager reçu par succession par le conjoint survivant.

En ce cas, le cessionnaire sera titulaire d'un droit démembré constitué sur la tête d'un tiers (le cédant) ; l'usufruit s'éteindra nécessairement au décès du cédant, sur la tête duquel il avait été constitué : le cessionnaire ne peut pas prolonger son droit au-delà du décès de l'usufruitier initial. Le cessionnaire n'est pas usufruitier, mais titulaire du droit démembré. En pareille hypothèse, l'usufruit s'éteint avec le décès de l'usufruitier en titre, c'est-à-dire de celui sur la tête duquel il a été établi, et non pas de celui qui ne serait que cessionnaire ou acquéreur de l'usufruit établi sur la tête d'un autre (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation », T. IV, p. 358).

Ceci a pour conséquence que le décès du cessionnaire de l'usufruit n'entraîne pas l'extinction de l'usufruit puisque la durée de l'usufruit dépend de la survie de l'usufruitier initial (Proudhon, précité, T. IV, p. 359). L'usufruit sera alors transmis à ses héritiers et cessera au décès de l'usufruitier initial (ou avant s'il a été prévu pour une durée déterminée).

Par ailleurs, à la mort naturelle, peuvent être assimilés la déclaration judiciaire de décès (c. civ. art. 88 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=88&idspad=LEGIARTI000006421335)) et l'absence, qui emporte, à compter de la transcription du jugement déclaratif, tous les effets du décès (c. civ. art. 128 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=128&idspad=LEGIARTI000006421817)).

Au décès de l'usufruitier ou lors de la cessation de l'usufruit, la consolidation se produit sur la tête du nu-propriétaire et la pleine propriété se reconstitue alors sur sa tête.

REMARQUE

On déconseillera donc de constituer un usufruit sur la tête d'une personne physique, son décès prématuré étant de nature à déjouer les prévisions économiques établies.

2. L'usufruitier personne morale

a) La durée de l'usufruit stipulée

319

Les personnes morales sont assujetties à un régime spécifique. Le caractère viager de l'usufruit ne leur est pas applicable. En effet, par l'effet des renouvellements successifs, il serait possible d'empêcher indéfiniment la reconstitution de la pleine propriété. La loi limite donc à trente ans la durée maximale possible de l'usufruit pour les personnes morales. Le législateur de 1804 a ainsi voulu éviter une perpétuelle dissociation de la propriété, comme elle a pu exister dans l'ancien droit, dans lequel les propriétés pouvaient perpétuellement être scindées entre domaine éminent et domaine utile.

Les travaux préparatoires du code civil indiquent que la durée a été fixée par référence à ce que proposait Domat (« On n'a pas adopté ici l'opinion du texte romain… mais… la doctrine de… Domat… qui lui-même devança l'opinion de notre code et n'eut pas de peine à dire qu'il y aurait eu bien plus de raisons de fixer cet usufruit à trente années seulement » : Présentation au corps législatif par M. Galli ; P.-A. Fenet, « Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil », T. XI, p. 212).

L'article 619 du code civil dispose donc que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

La question a pu se poser de savoir si ce texte relevait de l'ordre public ?

En d'autres termes, est-il contractuellement possible de stipuler une durée supérieure à celle prévue par la loi ?

Les travaux préparatoires du code civil pouvaient laisser penser que trente années constituent un maximum (« ... il s'agissait de déterminer la durée d'un usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ; et l'on a cédé à des vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les différentes dispositions que présentait à cet égard le droit romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété » : Gary : Discussion devant le corps législatif, P.-A. Fenet, précité, T. XI, p. 240).

Ce qu'a confirmé la jurisprudence en précisant que ce texte est d'ordre public. Tout d'abord, un jugement du TGI de Béthune du 26 avril 1960 a rappelé *«... que cette limitation dans le temps de l'usufruit des collectivités a été adoptée dans le souci de laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété ; qu'il en résulte que cette disposition, fondée sur tel motif de politique économique, doit être considérée comme d'ordre public...* » (cité par S. Grimaldi, « Le caractère viager de l'usufruit », thèse Paris II, p. 56, note 73).

Certes, le trouble a été jeté par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen (1re ch. civ., 24 janv. 1995 ; F.-D. Poitrinal, « L'usufruit réservé par une personne morale », Revue Droit en Patrimoine 1996, p. 46 ; Defrénois 1996, T. I, p. 392, obs. C. Atias ; JCP G 1995, T. IV, 1360) qui avait admis qu'une personne morale cède la nue-propriété d'un bien dont elle se réserve l'usufruit pour toute sa propre durée, supérieure à trente ans. Cet arrêt a été très justement critiqué par une doctrine unanime.

La Cour de cassation a nettement tranché le débat (cass. civ., 3e, 7 mars 2007, BC III n° 36 ; RJDA 7/07 n° 793 ; JCP N 2007 n° 1219 note H. Hovasse) en cassant un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait validé un contrat dérogeant à la règle instituée par l'article 619 du Code civil, lui déniant le caractère d'ordre public. Aux termes d'un attendu dépourvu de toute ambiguïté la Cour de cassation a précisé : *« Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la Cour d'appel a violé le texte susvisé »*.

Néanmoins, comme il est possible de dissocier la personne dont le décès entraînera l'extinction du droit d'usufruit et celle qui détient ce droit, il peut être envisagé de constituer un usufruit au profit d'une personne morale, mais pour la durée de vie d'une personne physique déterminée. En pareil cas, la Cour de cassation a récemment jugé (cass. com. 26 sept. 2018, n° 16-26.503 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=16-26503&sp=/juri/cass/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/37/47/39/JURITEXT000037473955.xml&date=0002-11-30)) que l'usufruit qui profite alors à la société conserve son caractère fondamentalement viager, malgré la borne trentenaire de l'article 619 du Code civil : la réponse n'était pas évidente car la situation est très différente du cas dans lequel l'usufruit a été préconstitué sur la tête d'une personne physique puis cédé ou apporté à une personne morale. L'arrêt consacre un peu plus la possibilité de dissocier la durée de l'usufruit de sa titularité.

En revanche, cette décision met en lumière le doute persistant quant au champ d'application de l'article 619 du Code civil (disposition dont il doit être admis qu'elle est d'ordre public) : consacrant la nature exclusivement viagère de l'usufruit dans l'hypothèse en cause, l'arrêt viendrait au soutien de la thèse suivant laquelle la durée d'un tel usufruit pourrait alors totalement échapper à l'article 619 du Code civil ; une telle analyse permettrait de considérer que l'usufruit ne s'éteindrait en toute hypothèse qu'au décès de la personne physique sur la tête de laquelle il a été constitué, sans égard au butoir de 30 ans donc même si la vie de la personne physique devait excéder cette durée.

Une telle approche n'est pas consacrée et la jurisprudence récente, précitée (cass. com. 26 sept. 2018, n° 16-26.503 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=16-26503&sp=/juri/cass/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/37/47/39/JURITEXT000037473955.xml&date=0002-11-30)) ne permet pas de trancher cette question. Ce point reste donc, à ce jour, incertain.

b) La disparition de la personnalité morale

320

La question des conséquences de la disparition de la personne morale avant le terme stipulé, par suite de dissolution ou de fusion (cf. supra), ne connaît pas de réponse certaine.

Pour certains, il convient d'assimiler purement et simplement la disparition de la personne morale avec la mort de la personne physique, ce qui justifierait donc que l'usufruit se trouverait automatiquement éteint par la disparation de l'usufruitier personne morale (Aubry et Rau, t. II, paragraphe 234, n° 443 ; Demolombe, « Traité de la distinction des biens », Paris 1866, T. 2, p. 574, n° 670). Cette solution semble devoir être appliquée au moins à l'hypothèse où l'usufruit a été constitué au profit de la personne morale, sans référence à la durée de vie d'une personne physique.

Mais l'analyse pourrait être différente :

-lorsque l'usufruit a été préconstitué sur la tête d'une personne physique avant d'être cédé ou apporté à la personne morale ;

-et lorsque l'usufruit a été constitué au profit de la personne morale mais en référence à la durée de vie d'une personne physique.

Dans ces deux cas, le risque de perpétuité de l'usufruit détenu par la personne morale n'existe pas, de sorte qu'il pourrait être défendu que l'usufruit survive à la durée de vie de la société. Une telle approche, incertaine à ce jour, serait au surplus respectueuse de la réalité économique de ces situations puisque cela éviterait de frustrer les associés ou créanciers de la société.

Cette dernière analyse pourrait également être étendue, avec moins de conviction, à l'usufruit constitué au profit de la personne morale sans référence à la durée de vie d'une personne physique, compte tenu de la limite trentenaire, qui retire également tout risque de perpétuité.

B. La perte totale de la chose

321

L'usufruit ne s'éteint que si la chose est périe en totalité (c. civ. art. 617 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=617&idspad=LEGIARTI000020616161)). Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste (c. civ. art. 623 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=623&idspad=LEGIARTI000006429665)).

On est alors conduit à distinguer la perte matérielle de la perte juridique. Dans le premier cas, l'usufruit ne peut plus s'exercer, faute d'objet. Le second vise principalement l'hypothèse de dépossession forcée comme l'expropriation.

1. La perte matérielle

322

La règle s'applique aux usufruits mobiliers ou immobiliers. Ainsi, l'usufruitier de titres d'une société ayant fait faillite et radiée de la cote subirait une perte matérielle.

Des règles spécifiques ont été édictées pour les immeubles. Concernant ces derniers, l'article 624 du code civil opère une distinction :

-si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et si ce bâtiment est détruit par un incendie ou un autre accident, ou s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux ;

-si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment fait partie, l'usufruitier jouira du sol et des matériaux.

La détermination de la perte totale est une question de fait, relevant de l'interprétation souveraine du juge du fond.

Toutefois, la perte de la chose n'entraîne pas l'extinction de l'usufruit que lorsqu'elle résulte d'un cas fortuit. Si elle est imputable à la faute du nu-propriétaire, de l'usufruitier ou d'un tiers, l'usufruit ne s'éteint pas si celui-ci peut être reporté, par le jeu de la subrogation réelle, sur l'indemnité à laquelle le propriétaire peut avoir droit à la suite du sinistre (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 459) ou sur l'immeuble reconstruit à l'aide de cette indemnité (J.-Cl. Not. Rép., V° Usufruit, Fasc. 80, n° 12 et s.). Cette question sera développée spécifiquement ci-après.

2. La perte juridique

323

Lorsque la vente a lieu de gré à gré, le prix est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de la valeur de leur droit respectif (c. civ. art. 621 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=621&idspad=LEGIARTI000006429647) al. 1er in limine) sauf accord contraire des parties (c. civ. art. 621 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=621&idspad=LEGIARTI000006429647) al. 1er in fine : quasi-usufruit, remploi en démembrement par subrogation...).

En revanche en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article L. 321-2 du code de l'expropriation prévoit une indemnité unique sur laquelle l'usufruitier exerce un quasi-usufruit. La notification de l'enquête préalable par l'administration doit être faite à la fois au nu-propriétaire et à l'usufruitier. L'ordonnance d'expropriation revêtue de l'autorité de la chose jugée entraîne extinction de l'usufruit en tant que droit réel. Il devient un simple droit de créance (J.-Cl. Not. Rép., V° Usufruit, Fasc. 80, n° 18).

II. Les effets de l'extinction de l'usufruit

A. Les effets généraux de l'extinction de l'usufruit

1. Les conséquences civiles

324

L'article 617 du code civil est clair. L'usufruit s'éteint, il n'est pas transmis. La pleine propriété est alors automatiquement reconstituée sur la tête du nu-propriétaire. Par suite de l'extinction de l'usufruit, ce dernier retrouve la totalité des prérogatives de la propriété, par la disparition de la charge qui la grevait (S. Grimaldi, thèse précitée, p. 41). Il retrouve alors immédiatement le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les fruits.

Les comptes devront alors être faits entre eux à raison notamment des dégradations ou des travaux de grosses réparations effectués par l'usufruitier.

2. Les conséquences fiscales

325

L'article 1133 du CGI n'est que la traduction fiscale de l'article 617 du code civil. Aux termes de ce dernier texte, l'usufruit s'éteint, il ne se transmet pas. Il n'y a donc pas de mutation d'usufruit, du moins lorsque l'usufruit expire par le temps pour lequel il a été accordé ou le décès de l'usufruitier (il peut en aller autrement en cas de renonciation par l'usufruitier à son droit : Marc Iwanesko, « La renonciation à usufruit », Bulletin Patrimoine Francis Lefebvre 06/2008).

Faute de transmission, il ne peut exister de taxation (hormis les hypothèses spécifiques visées par l'article 751 du CGI).

Dans la logique des droits d'enregistrement, l'article 1133 du CGI dispose donc que (sous réserve des dispositions de l'article 1020) *« ... la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier... »*. La consolidation s'opère donc sans impôt.

B. Les effets particuliers dans les relations usufruitier / nu-propriétaire

326

L'entreprise usufruitière titulaire d'un usufruit temporaire doit donc restituer la chose objet de l'usufruit.

Titulaire d'un droit sur la chose d'autrui, elle est tenue d'une part de conserver la substance de la chose (c. civ. art. 578 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=578&idspad=LEGIARTI000006429233)), d'autre part des réparations d'entretien et des grosses réparations dues à raison du défaut de réparations d'entretien (c. civ. art. 605 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=605&idspad=LEGIARTI000006429496)) et enfin de la restituer dans l'état où elle l'a reçue.

1. Les droits de l'entreprise usufruitière

327

Elle devient créancier du nu-propriétaire à raison des avances qu'elle aurait pu faire au regard des sommes et charges qui peuvent grever la propriété en application de l'article 609 al. 3 du code civil et les intérêts lui en sont dus au jour de la cessation de l'usufruit (Delastre, « L'extinction de l'usufruit », Thèse Paris 1884, p. 185).

Concernant les améliorations apportées à la chose il convient de distinguer les travaux d'entretien, les simples améliorations, les travaux de grosses réparations et les additions de construction.

a) Les travaux d'entretien

328

En vertu de l'article 605 du Code civil, les réparations d'entretien incombent définitivement à l'usufruitier. Elles sont la contrepartie de la jouissance en application de l'adage « Ubi emolumentum, ibi onus » (là ou est l'avantage, là doit être la charge).

b) Les simples améliorations

329

Il résulte de l'article 599 al. 2 du code civil : *« De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée »*.

Il en résulte que, sauf convention contraire, les améliorations profitent au nu-propriétaire sans contrepartie.

S'agissant d'une disposition légale, il ne peut en résulter ni abus de bien social, ni acte anormal de gestion. Sur ce fondement, l'administration serait par conséquent mal fondée à prétendre à la réintégration d'une indemnité dans les résultats de l'entreprise usufruitière au prétexte d'une soi-disant renonciation à un profit.

c) Les travaux de grosses réparations

330

Les travaux de grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire [Toutefois, si elles résultent du défaut d'entretien, elles sont supportées par l'usufruitier (c. civ. art. 605 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=605&idspad=LEGIARTI000006429496))].

Il en résulte que si l'usufruitier a financé les travaux de grosses réparations, soit de son propre chef, soit par suite du refus du nu-propriétaire de les exécuter [car sauf stipulation contraire, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations ni obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 599 du code civil (cass. civ., 3e, 10 juillet 2002, n° 00-22158 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=00-22158&sp=/juri/inca/global/civile/JURI/TEXT/00/00/07/43/91/JURITEXT000007439177.xml&date=2002-07-10))], elle sera indemnisée par le nu-propriétaire du montant de la plus-value (A. Chappert, « Le passif successoral et le fisc », Defresnois 1992, art. 35234, spéc. n° 80) à la cessation de l'usufruit (cass. civ. 17 juillet 1911, DP 1911.1.547 ; Paris, 31 octobre 1961, Gaz. Pal. 1962.1.75 ; trib. gr. inst. Pontoise, 17 mars 1976, Gaz. Pal. 1976.2.573, note Plancqueel).

Attention, l'administration pourrait reprocher à l'entreprise usufruitière de ne pas exercer ce droit d'indemnisation auprès du nu-propriétaire et ainsi réintégrer cette indemnité dans son résultat, qu'elle ait été ou non perçue.

d) Les constructions nouvelles et additions de constructions

331

Compte tenu des spécificités qui y président et des conséquences financières en jeu, cette question sera traitée ci-après de manière développée.

e) Les charges imposées à la propriété

332

Il résulte de l'article 609 du code civil qu'à l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. Le nu-propriétaire tiendra donc compte des sommes en cause au nominal à l'usufruitier en vertu du principe du nominalisme monétaire, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus.

Il s'agit du remboursement d'une créance. Elle ne constitue donc pas un profit pour l'usufruitier au sens fiscal.

Le défaut de remboursement de l'usufruitier (par hypothèse une société relevant des BIC, des BNC ou de l'IS) est susceptible de constituer un acte anormal de gestion ou un abus de biens social.

2. Les obligations de l'entreprise usufruitière

333

Au moment de la constitution de l'usufruit, la loi (c. civ. art. 600 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=600&idspad=LEGIARTI000006429450)) impose que soit dressé un état de l'immeuble (cf. supra).

Sa fonction essentielle consiste à décrire la situation matérielle des immeubles dans le but de déterminer les éventuelles indemnités à la charge de l'usufruitier ou de sa succession dues à raison de son éventuel défaut d'entretien. En effet, l'usufruitier devra alors restituer l'immeuble dans l'état où il l'a reçu. S'agissant d'un corps certain, la restitution doit en effet avoir pour objet la chose même qui a été délivrée à l'usufruitier.

Ce document servira de preuve de l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance.

L'établissement de ce document est d'autant plus important qu'en son absence, la charge de la preuve incombe au demandeur (c. civ. art. 1315 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1315&idspad=LEGIARTI000032041961)). Le nu-propriétaire qui entendrait contester l'état de l'immeuble au moment de la fin de l'usufruit en supporterait alors les conséquences. Il lui appartiendrait de prouver par tous moyens quelle était la consistance des biens soumis à l'usufruit lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier (CA Paris 15 septembre 1993 D. 1993.IR.236).

REMARQUE

Compte tenu du risque élevé de perte d'un document sous seing privé, la solution la plus sûre consiste à annexer ce document à la minute de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble. S'il s'agit d'une cession de droits sociaux effectuée par acte sous seing privé, compte tenu de la modicité du coût, on conseillera le dépôt de ce document au rang des minutes d'un notaire.

C. Les effets à l'égard des tiers

334

Les tiers dont il s'agit ici sont les tiers qui ont acquis des droits sur l'usufruit lui-même ou sur un bien soumis à usufruit. Il en va ainsi de ceux auxquels l'usufruitier aurait transmis son droit et de ceux auxquels il a passé bail.

1. L'extinction de l'usufruit par l'arrivée du terme pour lequel il a été stipulé

335

Les baux régulièrement conclus sont opposables au nu-propriétaire. Ce dernier est alors considéré comme le bailleur avec tous les droits et obligations que cela comporte (rép. civ. D. Usufruit, n° 157). Il est tenu envers le preneur de toutes les obligations nées du contrat et notamment de l'obligation de garantie contractée par l'usufruitier envers le locataire (R. Bouquillard, « Le contentieux des actes juridiques portant sur un immeuble grevé d'usufruit », Thèse Paris II, 1992, p. 60).

2. L'acquisition successive ou concomitante de l'usufruit et de la nue-propriété par un tiers

336

En cas d'acquisition, par le nu-propriétaire, d'un usufruit préconstitué au profit d'un tiers, le cessionnaire de l'usufruit n'est pas l'usufruitier visé par l'article 617 du code civil. Il n'y a donc pas extinction de l'usufruit au sens de ce texte, faute de véritable consolidation (cass. civ. 3e, 26 janvier 1972, BC III n° 69 ; JCP G 1972, II, 17104, note Goubeaux ; RTD civ. 1972, p. 619, obs. Bredin : « … Vu l'article 617 du Code civil ; attendu qu'en vertu de ce texte, l'extinction de l'usufruit par consolidation suppose la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; qu'à cet égard, le cessionnaire de l'usufruit ne saurait être assimilé à l'usufruitier… »).

Le nouveau propriétaire est donc tenu, en sa qualité d'ayant droit de l'usufruitier, de garantir la pérennité du bail au locataire mis en place par l'usufruitier (cass. civ. 3e, 26 janvier 1972 précité).

Chapitre V - Usufruit et fusion de sociétés

I. Définition et effets juridiques de la fusion

337

L'article 3 de la 3e directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978 définit la fusion par absorption comme *« L'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d'actions de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, ou, à défaut, de valeur nominale, de leur pair comptable »*.

Ce texte a été transposé dans notre droit positif et le code de commerce dispose d'une part qu'*« Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent »* (c. com. art. L. 236-1 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L236-1&idspad=LEGIARTI000047590816)), d'autre part que *« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »* (c. com. art. L. 236-3 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L236-3&idspad=LEGIARTI000047590799)).

Il en résulte donc la dissolution sans liquidation de l'absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à l'absorbante. L'absorbée disparaît alors *« La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse d'exister. »* (art. 19 de la directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978), ce que confirme la Cour de cassation : *« Une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations »* (cass. com. 16 février 1988, BC IV n° 69, JCP E 1988.I.15177, obs. J.-J. Caussain et A. Viandier).

II. Conséquences pratiques au regard de l'usufruit détenu par la société absorbée

338

Que se passe-t-il lorsqu'une société détient un usufruit à l'actif de son bilan et qu'elle fait l'objet d'une fusion-absorption ?

Quel est le devenir de l'usufruit détenu par l'absorbée ?

Pour certains, la disparition de la personnalité morale de la société, équivaut juridiquement à la mort d'une personne physique. Or, on sait que l'usufruit ne peut survivre à la personne sur la tête de laquelle il a été constitué (cf. supra).

Il en résulte que, selon cette analyse, du seul fait de la fusion, l'usufruit détenu par l'absorbée va s'éteindre et rejoindre la nue-propriété (M. Iwanesko, « Fusion de sociétés : conséquences de l'absorption d'une société titulaire d'un usufruit », Bulletin Patrimoine Francis Lefebvre, 06/2008). Il n'est pas possible d'en stipuler contractuellement la

prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par le propriétaire.

À ce jour, la majorité doctrinale considère que si l'existence légale de la personne morale vient à cesser, cette circonstance est assimilable à la mort d'une personne physique (Baudry-Lacantinerie et Chauveau T. VI 6, n° 732 ; Aubry et Rau, « Les Biens », T. II, § 234, n° 443).

Mais l'analyse pourrait être différente notamment (i) lorsque l'usufruit a été préconstitué sur la tête d'une personne physique avant d'être cédé ou apporté à la personne morale et (ii) lorsque l'usufruit a été constitué au profit de la personne morale, mais en référence à la durée de vie d'une personne physique : dans ces deux cas, le risque de perpétuité de l'usufruit détenu par la personne morale n'existe pas, de sorte qu'il pourrait être défendu que l'usufruit survive à la durée de vie de la société. Une telle approche, incertaine à ce jour, serait au surplus respectueuse de la réalité économique d'une opération de fusion.

Sur le plan fiscal en application de l'article 1133 du CGI, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. La disparition de la personne morale étant assimilable au décès d'une personne physique, la propriété sera reconstituée sur la tête du nu-propriétaire en franchise de droits.

REMARQUE

On déconseillera donc de faire détenir l'usufruit par la société opérationnelle si celle-ci est susceptible d'être fusionnée. On préférera alors loger l'usufruit dans une EURL détenue par cette dernière ou par la holding du groupe qui consentira alors un bail à la société opérationnelle.

Chapitre VI - La protection du chef d'entreprise nu-propriétaire : le pacte de préférence

339

On a pu s'interroger sur la situation du nu-propriétaire en cas de difficultés financières de l'entreprise usufruitière et notamment de la cession des actifs par le liquidateur.

Un palliatif peut certainement résider dans l'inclusion de la convention signée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un pacte de préférence.

I. Le principe

A. Définition

340

Le régime juridique du pacte de préférence est organisé par l'article 1123 du Code civil depuis la réforme du droit des contrats (ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) lequel dispose :

« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir ».

Appliqué à la vente, il constitue un engagement unilatéral du promettant pour le cas où il vendrait. Ce dernier n'est engagé avec le bénéficiaire que dans l'hypothèse où il décide de vendre.

B. Durée de validité

341

En pratique, la préférence accordée au bénéficiaire jouera pour la durée de l'usufruit constitué. S'il était stipulé pour une durée moindre, il cesserait au terme du délai prévu (H. Kenfack, « Validité du pacte de préférence », Droit et Patrimoine 01/2006, p. 46).

C. Le prix

342

Rien ne s'oppose à ce que le prix (ou une méthode de détermination du prix) soit fixé dès la signature du pacte (Planiol et Ripert, précité T. X, n° 184) mais la valeur résiduelle de l'usufruit étant inconnue, il sera stipulé que l'usufruit sera vendu au bénéficiaire au prix offert par le tiers qui se portera acquéreur. Étant précisé que ni la prédétermination du prix, ni la stipulation d'un délai ne sont des conditions de validité du pacte de préférence (cass. civ., 1re, 15 janvier 2003 : Jurisdata n° 2003-017314 ; JCP N 2003, n° 23, 1375, note L. Leveneur ; Defrénois 2003, art. 37767, p. 852, note Libchaber).

1. Les modalités pratiques

343

Le prix et les conditions de la vente seront notifiés au bénéficiaire qui bénéficiera contractuellement d'un délai pour faire jouer son droit de préférence. On prendra soin de réglementer précisément tant le mode d'exécution de l'obligation du promettant que les conditions auxquelles devra se soumettre le bénéficiaire pour accepter ou refuser l'acquisition offerte. On évitera la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment en cas de refus de retrait du destinataire ou d'absence de celui-ci. On préférera l'exploit d'huissier ou la remise contre récépissé. La réponse du bénéficiaire sera faite par la même voie.

Il sera stipulé que la notification vaudra offre de vente aux prix et conditions indiquées. En conséquence, en application de l'article 1589 du code civil, la vente sera parfaite dès l'acceptation du bénéficiaire (cass. civ., 3e, 16 juin 1999, BC III n° 142).

Il sera accordé au bénéficiaire un délai de réflexion pour répondre et, à compter de la notification, il aura un délai pour signer l'acte d'acquisition (le délai devra être suffisant pour lui permettre d'obtenir un concours bancaire). Il a été jugé que cette option avait un caractère définitif (cass. civ., 3e, 22 septembre 2004, BC III n° 157). À défaut de réponse ou de signature dans le délai prévu, le bénéficiaire sera forclos.

Afin d'éviter toute ambiguïté sur la computation des délais, on fera renvoi aux modalités prévues par le code de procédure civile (en ce sens, V° J. Guirec Raffray : Interprétation et rédaction des pactes de préférence : JCP N 1991, I, p. 471).

2. Formalités

344

Le pacte de préférence n'est en lui-même soumis à aucune condition de forme particulière. Il peut être fait sous forme authentique ou sous seing privé. En pratique, le pacte figurera en matière immobilière dans la convention de répartition de charges signée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

La publicité foncière du pacte de préférence est facultative et destinée à l'information des tiers. Il ressort en effet d'un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation (cass. civ., 3e, 16 mars 1994, BC III n° 58 ; Defrénois 1994, art. 35897, p. 1164, note L. Aynes ; J. Maury, La protection du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence publié : JCP N 1994, I, p. 341) que le pacte de préférence constitue une simple promesse unilatérale conditionnelle n'affectant en aucune manière le droit du propriétaire de disposer.

La publicité foncière n'est donc pas obligatoire, mais facultative. Le service de publicité foncière ne publiera le pacte que s'il est spécialement requis dans l'acte d'y procéder. Le pacte constituera alors une disposition indépendante, rendant exigible la contribution de sécurité immobilière de 0,10 % pour la détermination de l'assiette de laquelle les parties fourniront une déclaration estimative.

En pratique, l'exécution du pacte suppose qu'il soit publié au fichier immobilier, afin d'être connu des tiers et notamment du liquidateur, ce qui implique qu'il soit établi par acte authentique. Il résulte en effet de l'article 710-1 du code civil que tout acte doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire et que le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière.

En matière de cession de parts sociales, le pacte figurera dans l'acte de cession. La publicité en sera assurée par le dépôt au greffe de l'acte de cession.

II. Les effets du pacte de préférence

A. À l'égard du promettant

1. La nature de l'engagement

345

À l'égard du promettant, le pacte ne constitue pas un engagement de vendre, mais une obligation de faire, consistant à donner la préférence d'acquisition au bénéficiaire (Aubry et Rau, « Droit civil français », T. V, 6e éd., par Esmein, § 349, texte et note 12-7). Lorsque le promettant est une personne physique, sauf stipulation contraire (cass. civ., 1re, 6 novembre 1963 : D. 1964, p. 119 ; RTD civ. 1964, p. 728, obs. Chevallier), son décès n'éteint pas l'obligation résultant du pacte qui passe indivisiblement à ses héritiers et représentants qui sont tenus de l'exécuter (Aubry et Rau, précité, T. V, § 349, texte et note 13-9).

2. La sanction du défaut de respect du pacte

346

La vente à un autre que le bénéficiaire au mépris des dispositions du pacte de préférence ouvrira à son bénéficiaire la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sauf à prouver que le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, conditions dont la réunion permettra au bénéficiaire de demander également la nullité d'acte passé en violation du pacte ou même la substitution au tiers dans le contrat conclu.

Il s'agit de la consécration par la loi de la Jurisprudence de la Cour de cassation (cass. ch. mixte, 26 mai 2006 ; Jurisdata n° 2006/033690 ; JCP N 2006, n° 36, 1278, 2, p. 1542, obs. Piedelièvre ; Defrénois 2006, n° 15-16, art. 38433, p. 1206, note E. Savaux ; cass. civ., 3e, 31 janvier 2007 : Jurisdata n° 2007-037159 ; cass. civ., 3e, 14 févr. 2007 : Jurisdata n° 2007-037358 ; Dr. sociétés 2007, n° 4, comm. 63, p. 26, note H. Lecuyer ; cass. civ., 3e, 25 mars 2009 : Jurisdata n° 2009-047548 ; Defrénois 2010 n° 4, art. 39075 p. 454, note Y. Dagorne-Labbe) qui admettait dès avant la réforme du droit des contrats de 2016 la substitution du bénéficiaire d'un pacte de préférence dans les droits d'un tiers acquéreur : « Si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ».

B. À l'égard du bénéficiaire

347

Le pacte de préférence confère au bénéficiaire un simple droit de créance (Aubry et Rau, précité, T. V, § 349, texte et note 13-8 ; cass. civ., 1re, 20 février 1962). Il n'est donc jamais tenu d'acheter, mais l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente (cass. civ., 3e, 22 septembre 2004 ; Jurisdata n° 2004-024865 ; JCP N 2006, n° 14, 1147, p. 711, note M. Dagot).

Le défaut de respect des dispositions du pacte par le promettant permet au bénéficiaire d'obtenir des dommages-intérêts, voire l'exécution forcée (cf. supra).

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le pacte de préférence est en principe transmissible aux héritiers des parties. Il est toutefois possible de stipuler de conférer à cette obligation un caractère strictement personnel (cass. civ., 1re, 24 février 1987 : JCP N 1987, prat. 325, p. 577). Il ne profite alors qu'au bénéficiaire et pas à ses ayants droit. S'agissant d'une cession de créance, les formalités prévues à l'article 1690 du code civil devront être respectées (*« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »*)

REMARQUE

Afin d'éviter toutes difficultés le pacte précisera expressément si son bénéfice est ou n'est pas cessible ou transmissible.

C. À l'égard des procédures collectives et du liquidateur

348

La doctrine considère que l'existence d'un pacte de préférence est conciliable avec une adjudication. En effet, cette opération, quand bien même serait-elle forcée, demeure une vente (P. Voirin, « Le pacte de préférence », JCP 1954, I, 1192).

La Cour de cassation a jugé qu'un pacte de préférence doit être respecté par le liquidateur (cass. com. 13 février 2007, BC IV n° 34 ; JCP N 2007, n° 8, act. 219 ; D. 2007, n° 10, p. 648, note Cl. Lienhard ; Act. proc. coll. 2007, n° 5, p. 5, note C. Regnaut-Moutier). Le liquidateur judiciaire est tenu de respecter le pacte de préférence stipulé au profit d'un tiers. *« Attendu que pour accueillir la demande de la société Mister Bed Lille, dire que la clause insérée dans le bail du 29 avril 1993 stipulant un droit de préférence au profit de la SCI est privée d'effet et rejeter la demande de cette dernière tendant à contraindre le liquidateur judiciaire à lui céder le droit au bail, l'arrêt retient que cette clause se trouve privée d'effet en raison du caractère définitif de la cession judiciaire intervenue, à l'occasion des opérations de liquidation judiciaire de la société Belle Étoile. Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder l'unité de production était tenu de respecter la clause du bail stipulant un droit de préférence au profit du bailleur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; »*

Que la liquidation soit amiable ou judiciaire, le prix est inconnu. Les droits du bénéficiaire du pacte devront être précisés. On stipulera que la mise en adjudication lui sera signifiée dans un certain délai déterminé. On pourra prévoir qu'il aura alors la faculté de se substituer au dernier enchérisseur aussitôt l'extinction du dernier feu ou dans un délai déterminé. À défaut, le droit de préemption serait purgé. L'éventuelle déclaration de surenchère lui sera dénoncée dans les mêmes formes et délai qu'à l'adjudicataire.

Chapitre VII - La problématique de la construction sur sol d'autrui

349

Le code civil ne traite pas du sort des constructions édifiées sur un immeuble démembré. Le seul texte existant (c. civ. art. 599 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=599&idspad=LEGIARTI000006429433)) vise les améliorations : « L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur des choses en fût augmentée ».

Dès lors que se passe-t-il si une construction est édifiée ?

En pratique, quatre questions principales se posent :

Qui est titulaire du droit de construire ?

Quel est le sort des constructions édifiées ?

L'usufruitier qui a construit peut-il prétendre à une indemnité au terme de l'usufruit ?

Quelles sont les conséquences fiscales de cette situation ?

I. Qui est titulaire du droit de construire ?

350

Il faut combiner les règles spécifiques du code de l'urbanisme avec les principes gouvernant les droits de propriété démembrés.

Le code de l'urbanisme ne précise pas si l'usufruitier a le droit ou non de déposer un permis de construire. L'article L. 421-1 de ce code dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire et l'article R. 423-1 précise que les demandes de permis de construire sont déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés par le propriétaire.

S'agissant de démembrement, on sait que le nu-propriétaire est tenu envers l'usufruitier d'une obligation d'abstention et doit le laisser jouir, l'usufruitier quant à lui, n'ayant que l'usage du bien d'autrui, doit en respecter la substance.

Dès lors, qui du chef d'entreprise propriétaire ou de l'entreprise usufruitière a le droit de demander un permis de construire ?

A. Le nu-propriétaire

351

Les principes qui gouvernent les droits démembrés conduisent certainement à interdire au nu-propriétaire d'édifier une construction.

En effet, ce dernier est tenu de laisser jouir l'usufruitier. Or, l'article 599 du code civil dispose que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire au droit de l'usufruitier.

Il est donc tenu d'une obligation d'abstention à son égard et ne peut modifier la chose sans l'accord de ce dernier.

La doctrine en conclut qu'il ne peut, en principe, édifier des constructions sur le terrain démembré sans l'accord de l'usufruitier. Toute construction par le propriétaire constituerait alors une atteinte aux droits de l'usufruitier (103e Congrès des Notaires de France, La division de l'immeuble, p. 42).

La jurisprudence a toutefois admis l'accord tacite de l'usufruitier quand ce dernier a concouru à l'acte d'emprunt souscrit par le nu-propriétaire pour financer la construction (cass. civ., 3e, 7 février 1979, JCP 1979, T. IV, 127).

En effet, il n'est pas dans les pouvoirs d'un nu-propriétaire de construire sur un terrain démembré et cela ne peut se concevoir qu'avec le plein accord de l'usufruitier. Observons qu'il a été jugé en pareille hypothèse que l'usufruitier avait renoncé à l'usufruit (cass. civ., 1re, 31 octobre 1989, n° 88-14343 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=88-14343&sp=/juri/inca/global/civile/JURI/TEXT/00/00/07/08/88/JURITEXT000007088832.xml&date=1989-10-31)) et consent donc, au nu-propriétaire, une donation indirecte de l'usufruit. «... Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Judet avait autorisé son fils, non seulement à utiliser deux caves d'immeuble dont elle s'était réservé l'usufruit, mais à les restaurer entièrement, de telle sorte qu'une telle autorisation ne pouvait revêtir un caractère précaire, la Cour d'appel a pu estimer qu'elle avait renoncé de façon certaine et non équivoque à son droit d'usufruit ; qu'elle en a exactement déduit que Philippe Dauliach avait recouvré la pleine propriété des deux caves en question... ».

On sait que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour admettre que la renonciation à usufruit est unilatérale (M. Iwanesko, « La renonciation à usufruit », Bulletin Patrimoine Francis Lefebvre, 06/2008) et n'est soumise à aucune condition de forme dès lors qu'elle est certaine (cass. civ., 3e, 7 février 1979, D. 1979, I.R. 396) ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fonds.

L'usufruitier peut renoncer unilatéralement à son droit donc sans le consentement du propriétaire (Baudry-Lacantinerie et Chauveau, « Traité théorique et pratique de droit civil », 3e éd., T. 6, n° 761 ; Aubry et Rau, « Droit civil français », 7e éd., T. 2, par Esmein, § 226 et s ; Planiol et Ripert, T. 3, par Picard, n° 866 ; Req. 16 mars 1870,

D. 70.1.329 ; contra : Weill, Terre et Simler, Droit civil. « Les biens », 3e éd. n° 774).

Il en résulte que nous sommes extrêmement réservés sur le procédé consistant à démembrer un terrain nu et à procéder ensuite à une construction aux frais et à l'initiative du nu-propriétaire. En effet, en pareille hypothèse, l'administration fiscale ne pourrait-elle pas se prévaloir de l'arrêt du 31 octobre 1989 précité, pour considérer que l'usufruitier avait renoncé à son droit ? S'il était fait droit à cette demande, la pleine propriété serait alors reconstituée entre les mains du nu-propriétaire, la renonciation éteignant immédiatement l'usufruit (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, spéc. n° 474).

B. L'usufruitier

352

L'usufruitier doit conserver la substance du bien objet de son droit (c. civ. art. 578 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=578&idspad=LEGIARTI000006429233)). Et la substance d'un bien se définit comme son affectation normale, sa destination (E. Dockes, « Essai sur la notion d'usufruit », RTD civ. 1995, p. 491).

Il peut toutefois être autorisé par le juge à porter atteinte à la substance de la chose dans le but de poursuivre une exploitation avantageuse, qui eût été compromise sans cela (Req., 8 avril 1845, DP 45.1.214). La situation n'est pas rare. Une entreprise évolue, modifie, étend ses activités. Un changement d'activité peut même survenir.

Le Code civil (c. civ. art. 599 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=599&idspad=LEGIARTI000006429433)) autorise l'entreprise usufruitière à apporter des améliorations pour mieux satisfaire sa jouissance et elle peut user de ce droit sans consulter le propriétaire puisqu'il lui est seulement défendu de répéter les impenses (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation », T. 3, n° 1432) ; en revanche, elle ne peut faire de changements qui empirent la situation du propriétaire (Proudhon, précité, T. 3, n° 1433).

S'agissant de constructions nouvelles, le fait de savoir si l'usufruitier peut, sans l'accord du nu-propriétaire, édifier des constructions nouvelles est controversé en doctrine. Certains auteurs considèrent qu'il faut appliquer les mêmes règles que pour les transformations. Dès lors, l'usufruitier pourrait édifier toutes les constructions nécessaires à l'exploitation de l'immeuble et au maintien de sa destination (Rép. civ. Dalloz, V°Usufruit, n° 210). Pour d'autres, l'usufruitier ne peut construire dès lors qu'une construction nouvelle est susceptible d'entraîner une modification de la destination du bien ; ainsi, selon cette analyse, il pourrait effectivement être défendu qu'une construction nouvelle sur un terrain nu modifie la destination de la chose.

L'approche libérale, consistant à permettre, par principe, à l'usufruitier d'ériger des constructions nouvelles doit à notre sens prévaloir au regard tant de son opportunité économique qu'en considération de l'analyse juridique.

Au regard de l'opportunité économique, permettre à l'usufruitier d'édifier des constructions nouvelles est la seule manière d'autoriser une exploitation pleine et entière des utilités de la chose ; or, seul l'usufruitier maîtrise l'exploitation de la chose et est en situation de tirer profit de ses utilités.

L'analyse juridique conduit à la même conclusion : sauf exception, l'édification d'une construction nouvelle ne compromet pas la substance du bien ; au surplus, une telle approche semble confirmée par l'analyse de la jurisprudence récente (cass. 3e civ. 19 sept. 2012, n° 11-15.460) suivant laquelle l'accession n'opère pas immédiatement au profit du nu-propriétaire de sorte que l'usufruitier demeure plein propriétaire des constructions.

Par exception, certaines constructions nouvelles pourraient être de nature à porter atteinte à la substance du terrain de sorte que l'usufruitier devra s'en abstenir sauf à commettre un abus de jouissance susceptible d'être sanctionné sur le fondement de l'article 618 du Code civil (F. Deboissy, « Le sort des constructions édifiées par l'usufruitier », Études offertes au Doyen Philippe Simler, pp. 744 et s., spéc. n° 6).

C. Le nu-propriétaire pourrait-il s'opposer à la construction par l'usufruitier ?

353

Le code ne traite pas directement de la question. Proudhon (« Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation », T. 3, n° 1432) considère que le propriétaire ne peut, sans justes motifs, mettre obstacle aux constructions utiles édifiées par l'usufruitier. Un tel refus serait en effet de nature à paralyser une partie des revenus dans les mains de l'usufruitier.

Compte tenu de la stricte obligation résultant pour l'usufruitier des prescriptions de l'article 578 du code civil, la prudence doit conduire à régler cette question dans l'acte constitutif du démembrement. Pour éviter que le nu-propriétaire n'ait à supporter une construction non souhaitée, il pourra utilement être stipulé qu'un accord conjoint sera requis.

On ne peut en effet, exclure la possibilité pour le nu-propriétaire, d'intenter une action en déchéance de l'usufruit sur le fondement de l'article 618 du code civil.

II. Quel est le sort des constructions édifiées ?

354

Dès lors que les constructions ont été édifiées, la règle de l'accession joue-t-elle ?

La question a été controversée.

Selon une première opinion, le démembrement se reporte immédiatement sur la construction car l'accession joue automatiquement au fur et à mesure de la construction (H. L et J. Mazeaud, « Leçons de droit civil », T. II, n° 1592 ; dans le même sens G. Gilles : Des conséquences de l'extinction de l'usufruit, Thèse Paris 1912, p. 125). Son fondement réside dans l'article 551 du code civil qui dispose que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire.

Or, le droit d'accession serait conservé par le nu-propriétaire car son droit est de même nature que la propriété (F. Zenati, « Les biens », p. 254).

Un seul texte traite des droits de l'usufruitier sur les accroissements. L'article 596 du Code civil dispose qu' « il jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit ».

La doctrine classique défendait une interprétation stricte de ce texte, au motif qu'il s'agit d'un texte exceptionnel (Aubry et Rau, « Droit civil français », 7e éd. par P. Esmein, T. II, « Les Biens », n° 420 et note 41 p. 661). En outre, il était argué que le propriétaire ne pouvait avoir eu pour intention d'accorder à l'usufruitier la jouissance d'un bien ne lui appartenant pas encore (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 238).

D'autres auteurs précisent que si le droit de l'usufruitier s'étend à tous les accessoires qui dépendent de la chose au moment de l'ouverture de l'usufruit, il n'est guère possible de considérer comme accessoires de la chose les accroissements qu'elle reçoit par accession, et, le code étant muet, c'est le propriétaire seul qui, en vertu de son droit, doit bénéficier de ces accroissements (Planiol et Ripert, « Traité pratique de droit civil français », 2e éd., T. III ; « Les biens », par M. Picard, LGDJ, Paris 1952, n° 775 p. 768 et note 1 p. 769).

Mais, plus récemment, d'autres auteurs ont considéré que l'article 596 est l'une des applications du principe selon lequel l'usufruit d'une chose s'étend à ses accessoires (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, précité n° 238).

F. Zenati va dans le même sens : « L'accession, qui est une extension de l'objet de la propriété ne peut, pour cette raison, que profiter au propriétaire, à l'exception des fruits dont l'acquisition est liée à l'usage de la chose et constitue l'objet même de l'usufruit » (« Les biens », PUF Paris 1988, n° 232).

Cette analyse est donc favorable à ce que le droit de l'usufruitier s'étende aux constructions nouvelles.

Une telle approche impliquerait alors que si l'usufruitier a financé seul les constructions, il aurait alors immédiatement enrichi le nu-propriétaire de la valeur de la nue-propriété. Le risque encouru en pareille hypothèse pourrait alors ressortir de l'acte anormal de gestion, voire de l'abus de bien social. Pour pallier ce risque, le nu-propriétaire devrait alors rembourser immédiatement l'usufruitier de la valeur de la nue-propriété.

Selon une seconde opinion, l'accession serait différée à l'extinction de l'usufruit. L'usufruitier jouirait alors d'un droit de propriété temporaire jusqu'au terme du démembrement (Cridon-Bordeaux 1979, « La construction sur sol d'autrui » ; J.-Cl. Enregistrement, V° Succession fasc. 35 n° 53 ; E. Maguero : « Traité alphabétique des droits d'enregistrement », V° Construction, n° 49). La doctrine la plus récente va dans ce sens (F. Deboissy précitée n° 19) : il convient d'appliquer à l'usufruitier la jurisprudence qui prévaut à l'égard du preneur. Selon la Cour de cassation, ce dernier reste propriétaire jusqu'au terme du bail des constructions qu'il a édifiées (cass. civ., 3e, 4 avril 2002, BC III n° 71 « Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en application de l'article 555 du Code civil, le preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il avait régulièrement édifiées sur le terrain loué… »). Mme Deboissy observe avec justesse qu'il serait paradoxal que l'usufruitier ne bénéficie pas d'une protection identique à celle du preneur, outre que cela permet à l'usufruitier de restituer le bien dans l'état où il l'a reçu. En effet, ce dernier étant propriétaire des constructions, il peut les détruire, ce qui ne serait pas possible si l'accession avait joué. Il a en ainsi été jugé pour des plantations effectuées par l'usufruitier (cass. civ., 3e, 11 octobre 1968, BC III n° 377) : *« et sur le troisième moyen : attendu qu'il est tout aussi vainement reproché à l'arrêt d'avoir refusé à Francis X… Une indemnité pour l'abattage de cinquante peupliers effectué par son père sur des terrains dont ce dernier n'était qu'usufruitier, au motif que, les ayant plantés lui-même, il pouvait les enlever, alors que les plantations faites par l'usufruitier ne sont pas des fruits et constituent des améliorations qui appartiennent au nu-propriétaire. Qu'en effet, l'arrêt relevé justement qu'il ne peut être fait aucun grief à l'usufruitier lorsqu'il restitue le fonds dans l'état où il l'a trouvé. Qu'ainsi le moyen doit être écarté… ».*

Cette seconde analyse a été consacrée par la jurisprudence suivant laquelle « il n'existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, l'accession n'a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol » (cass. 3e civ. 19 sept. 2012, n° 11-15.460). L'usufruitier pourrait donc, sans l'accord du nu-propriétaire, détruire, avant extinction de l'usufruit, les constructions qu'il a édifiées.

III. L'usufruitier qui a construit peut-il prétendre à une indemnité ?

355

L'usufruitier ayant édifié une construction sur le terrain du nu-propriétaire est-il redevable d'une indemnité envers ce dernier ?

Avant de répondre à cette question, il importe de bien distinguer les réparations des améliorations. La charge des réparations incombe à l'usufruitier ou au nu-propriétaire, selon les critères prévus par les articles 605 et 606 du code civil.

Si les réparations d'entretien incombent définitivement à l'usufruitier, les grosses réparations incombent au nu-propriétaire.

Il en résulte que si l'usufruitier finance ces dépenses, le propriétaire sera tenu de lui rembourser la plus-value en résultant à la fin de l'usufruit.

La règle est différente en matière d'améliorations. L'article 599 du code civil, dispose que « l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée ».

Par « améliorations », il faut entendre tous travaux et opérations qui, n'étant pas commandés par la nécessité de la conservation ou de l'entretien de la chose, ont eu pour résultat de la compléter, de la rendre plus productive, plus utile ou plus agréable (Rép. civ. Dalloz, V° Usufruit, n° 498).

A. La jurisprudence

356

Deux arrêts très anciens ont dénié à l'usufruitier le droit d'obtenir une indemnité de la part du nu-propriétaire au terme du démembrement (cass. civ. 23 mars 1825, DP 1825.I, p. 249 ; cass. req. 4 novembre 1885, DP 1886, I, p. 361, rapp. Almeras-Latour ; S. 1886, 1, p. 113) au motif que la notion d'amélioration doit être très largement comprise et s'étend aux constructions nouvelles s'ajoutant au fonds et en augmentant la valeur ou les constructions ayant pour effet d'achever un bâtiment commencé ou d'agrandir un édifice préexistant.

Cet arrêt considère comme améliorations « soit les constructions nouvelles s'ajoutant au fonds et en augmentant la valeur, soit les constructions ayant pour effet d'achever un bâtiment commencé ou bien d'agrandir un édifice préexistant » (Req. 4 novembre 1885, DP 86.1.361 ; S. 86.1.113).

Si cette voie devait être suivie, cela empêcherait l'usufruitier d'invoquer l'article 555 du code civil. Ce texte permet en effet à ceux qui ont construit sur le terrain d'autrui d'obtenir une indemnité.

Mais l'usufruitier ne pourrait, à la cessation de l'usufruit, être assimilé, sous aucun rapport, à un tiers possesseur évincé. En effet l'usufruitier, agissant dans son propre intérêt, ne peut être assimilé au tiers qui agit dans l'intérêt du propriétaire (cass. civ. 23 mars 1825, DP 1825, I, p. 249, précité).

Le conseiller rapporteur Almeras-Latour (Req. 4 novembre 1885, précité) indique que l'usufruitier n'est pas dans la situation d'un propriétaire évincé ; il a détenu la chose en vertu d'un droit propre, de sorte qu'il n'est ni de bonne foi ni de mauvaise foi ; il a agi dans son intérêt, ou pour son agrément, et en a eu la jouissance durant sa vie, ce qui le rémunère indirectement. Il ne peut donc bénéficier ni de la théorie des impenses, ni de l'article 555 du code civil et ne pourrait donc, à la fin de l'usufruit, réclamer aucune indemnité au nu-propriétaire pour les constructions réalisées (G. Gilles, « Des conséquences de l'extinction de l'usufruit », Thèse Paris 1912, p. 97).

Par ailleurs, le législateur a eu le souci de ne pas imposer au propriétaire un remboursement onéreux, pour des travaux qu'il n'aurait peut-être pas effectués lui-même (Présentation du Doyen Gary au Tribunat cité par Proudhon, « Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation », T. 3, n° 1425). D'autre part, les impenses et améliorations sont faites par l'usufruitier dans son intérêt et les fruits qu'il a perçus sont la compensation de ce qu'il a dépensé pour les accroître (cass. civ. 23 mars 1825, précité).

En outre, les rédacteurs du code ont considéré que la durée viagère de l'usufruit permettait à son titulaire d'amortir son investissement (F. Barbier, « La nature juridique de l'usufruit », Thèse Lyon 1988, p. 350), les fruits qu'il a recueillis sont la compensation des impenses faites (Proudhon précité T. 3, n° 1427).

B. La doctrine

357

La doctrine dans son ensemble critique très vivement le courant jurisprudentiel qui tend à assimiler construction à réparation (Aubry et Rau, Droit civil français par Esmein, 7e éd., T. II, « Les biens », p. 705 ; Planiol et Ripert, T. 3, par Picard, n° 879 ; Mazeaud et Chabas, « Leçons de droit civil », T. 2, 2e vol., n° 1602, et Lectures, 75e Leçon ; Weill, Terre et Simler, Droit civil. « Les biens », 3e éd., n° 785).

Elle rappelle le sens du mot réparation : « Le mot réparation s'entend de tout ouvrage qu'on fait à une chose dégradée, afin d'en prévenir la ruine et de la remettre en l'état où elle doit être pour remplir convenablement les fonctions auxquelles elle est destinée. » (Proudhon, « Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie », 1re éd. 1824, T. IV, n° 1612). L'auteur observe que l'action de réparer suppose la préexistence de la chose. S'il en allait autrement, il s'agirait d'une construction neuve et non d'une réparation.

Par ailleurs, dans son discours au corps législatif, le Tribun Gary précisait que les améliorations apportées par l'usufruitier ne sont, aux yeux de la loi, que le résultat naturel d'une jouissance éclairée et qu'il ne doit pas être au pouvoir de l'usufruitier de grever d'avance le propriétaire de répétitions qui pourraient lui être onéreuses (P.-A. Fenet, « Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil », T. 11, p. 233).

Demolombe quant à lui précise que l'usufruitier a droit à une indemnité pour les grosses réparations qu'il a effectuées mais également pour les constructions dont le résultat n'aurait pas été seulement d'améliorer le fonds, mais de le transformer et d'en changer la substance et de faire par exemple d'un jardin, un hôtel (Demolombe, « Traité de la distinction des biens », 3e éd., T. 2, n° 643) et que ce texte n'est pas applicable aux constructions nouvelles, le mot réparations ayant ici un sens étroit et limité (Traité précité n° 645). Cet auteur considère que l'article 555 s'applique à l'usufruitier (Traité précité n° 643).

Delastre (« L'extinction de l'usufruit », Thèse Paris 1884, p. 189) considérait d'une part que le langage courant ne confond pas amélioration et construction nouvelle et d'autre part que l'équité devait conduire à indemniser le nu-propriétaire.

Certains font observer qu'il est paradoxal que l'usufruitier ait droit à une indemnité en cas de grosse réparation et ne puisse y prétendre en présence de construction nouvelle : selon cette approche, la Cour de cassation consacre une iniquité en octroyant au propriétaire un enrichissement considérable « aux dépens » de l'usufruitier (F. Terre et Ph. Simler, « Les biens », Dalloz 2002, n° 857).

C. Les conséquences pratiques

358

De l'impossibilité de principe pour l'usufruitier de solliciter une quelconque indemnité en fin d'usufruit sur le fondement de l'article 555 ou 599 du Code civil, résulte une vigilance particulière en pratique afin de prévenir toute iniquité au préjudice de l'usufruitier ; il faudrait, au fond, faire en sorte que l'usufruitier-constructeur puisse toujours tirer des constructions nouvelles édifiées par lui, un profit suffisant et raisonnable au regard des dépenses engagées.

En effet, la réalisation aux frais de l'usufruitier de constructions nouvelles (ou, plus généralement, d'améliorations), dont il ne serait pas en mesure de justifier qu'elles sont dans son intérêt serait susceptible d'être sanctionnée tant au niveau pénal, si l'usufruitier est une personne morale, sur le terrain de l'abus de bien social (ou de l'abus de confiance, selon la forme sociale) qu'au niveau fiscal, sur le terrain de l'acte anormal de gestion (ou de la donation indirecte), la Jurisprudence précitée du 19 septembre 2012 ne permettant pas d'exclure ce risque.

En outre, en cas de procédure collective ouverte contre l'usufruitier, le liquidateur pourrait être fondé à soutenir la confusion des patrimoines (c. com. art. L. 621-2 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L621-2&idspad=LEGIARTI000045178127)) fondée sur l'existence de flux anormaux entre les sociétés.

Dans le premier cas, les dispositions de l'article 599 du code civil font obstacle à l'indemnisation de l'usufruitier, qu'il s'agisse d'agrandissement d'une construction existante ou d'adjonction à une construction existante (F. Deboissy précitée, n° 42). L'acte anormal de gestion ne peut donc exister dès lors que la dépense effectuée a une contrepartie significative pour l'usufruitier.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.